

Unidad I – Introducción al Derecho de Sociedades

1. Aspectos Generales

2. Clasificación de las Sociedades

- A) Según su Giro u Objeto
- B) Según las Formalidades Requeridas para su Constitución
- C) Según sus Características
- D) Según la Responsabilidad de sus Socios
- E) Según el Interés Involucrado

3. Elementos Esenciales de Toda Sociedad

- A) Presencia de Dos o Más Socios
- B) Aporte de los Socios
- C) Objeto de la Sociedad
- D) Participación en las Utilidades y Contribución en las Pérdidas
- E) El Nombre de la Sociedad

Unidad II – Las Sociedades de Personas

1. La Sociedad Colectiva

2. Formación y Prueba de la Sociedad Colectiva

3. Menciones Mínimas de la Escritura de Sociedad Colectiva

4. Requisitos Esenciales de la Sociedad Colectiva

- A) Presencia de Dos o Más Socios
- B) La Obligación de Aportar
- C) El Objeto de la Sociedad
- D) Participación en las Utilidades y Contribución en la Pérdida
- E) La Razón Social

5. Administración de la Sociedad Colectiva

- A) Aspectos Generales
- B) Derecho de Oposición
- C) El Administrador Delegado
 - 1) Responsabilidad del Administrador Delegado
 - 2) Facultades del Administrador Delegado
- D) El Administrador Estatutario

6. Prohibiciones de los Socios en la Sociedad Colectiva

7. Duración de la Sociedad Colectiva

8. Obligación de Inscripción de la Sociedad Colectiva

9. Modificación de la Sociedad Colectiva

10. Disolución de la Sociedad Colectiva

- A) Causales de Disolución
 - 1) Expiración del Plazo o Cumplimiento de la Condición
 - 2) Finalización del Negocio por el cual se constituyó la Sociedad
 - 3) Insolvencia de la Sociedad
 - 4) Incumplimiento de la Obligación de Aportar
 - 5) Pérdida de la Cosa Aportada
 - 6) Muerte de uno de los Socios
 - 7) Mutuo Consentimiento de los Socios
 - 8) Renuncia de un Socio
- B) Efectos de la Disolución de la Sociedad Colectiva

11. Liquidación de la Sociedad Colectiva

12. Sociedad de Responsabilidad Limitada

13. Otras Especies de Asociación

Unidad III – Sociedades en Comandita

1. Aspectos Generales

2. Sociedad en Comandita Simple

3. Sociedad en Comandita por Acciones

Unidad IV – La Sociedad Anónima**1. Aspectos Generales**

- A) Antecedentes
- B) Concepto
- C) Clasificación de las Sociedades Anónimas

2. Constitución de la Sociedad Anónima

- A) Formación, Existencia y Prueba
- B) Menciones Mínimas de la Escritura
- C) Inscripción y Publicación del Extracto
- D) Nulidad Absoluta por Vicios en la Constitución
- E) Registro de Estatutos y Listas de Accionistas

3. El Capital Social, las Acciones y los Accionistas

- A) Clasificación de las Acciones
- B) Determinación del Capital
- C) Suscripción y Cesión de Acciones
- D) Libre Cesión de las Acciones
- E) Pago de las Acciones
- F) Tipos de Acciones
- G) Constitución de Gravámenes y Derechos Reales sobre las Acciones
- H) Aumentos de Capital
- I) Autoadquisición de Acciones
- J) Acuerdos de Reducción de Capital

4. Administración de las Sociedades Anónimas

- A) El Directorio
 - 1) Aspectos Generales
 - 2) Prohibiciones para ser Director
 - 3) Funciones del Director
 - 4) Facultades del Directorio
 - 5) Prohibiciones de los Directores
 - 6) Deber de Reserva de los Directores
 - 7) Conflictos de Interés
 - 8) Presunciones de Culpabilidad del Directorio
 - 9) Reuniones de los Directores
 - 10) Gerentes
 - 11) Director Independiente y Comité de Directores
- B) Inspectores de Cuentas y Auditores Externos
 - 1) En Sociedades Anónimas Cerradas
 - 2) En Sociedades Anónimas Abiertas
- C) Juntas de Accionistas
 - 1) Aspectos Generales
 - 2) Materias Propias de las Juntas de Accionistas
 - 3) Convocatorias a las Juntas de Accionistas
 - 4) Quóruns para la Adopción de Acuerdos
 - 5) Derecho a Retiro

5. Pago de los Dividendos**6. Sociedades Filiales y Coligadas****7. División, Transformación y Fusión de la Sociedad Anónima****8. Disolución y Liquidación de la Sociedad Anónima****9. Arbitraje****10. Responsabilidades y Sanciones**

Unidad V – Sociedad por Acciones

- 1. Aspectos Generales**
- 2. Constitución de la Sociedad por Acciones**
- 3. Normas Generales**
 - A) Responsabilidad de los Accionistas
 - B) Registro de Accionistas
 - C) Nombre, Domicilio y Objeto Social
- 4. Capital Social**
- 5. Resolución de Conflictos**
- 6. Pago de Dividendos**
- 7. Medios de Comunicación**
- 8. Traspasos de Acciones**

Unidad VI – Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

- 1. Introducción**
- 2. Constitución de la EIRL**
- 3. Administración de la EIRL**
- 4. Responsabilidad del Titular**
- 5. Transformación de una Sociedad en una EIRL**
- 6. Disolución de la EIRL**
- 7. Legislación Aplicable**
- 8. Sociedades por un Día**

Unidad I – Introducción al Derecho de Sociedades

1. Aspectos Generales

La asociación entre personas es parte de la realidad, así como la colaboración para la realización de actividades mercantiles, lo cual es cada vez más común en la vida cotidiana.

Antiguamente, el modelo societario tenía como fin la protección de los patrimonios de los socios, para luego evolucionar a un concepto que giraba en torno a la asociación de personas (sociedades colectivas y de responsabilidad limitada), y posteriormente, a las sociedades de capital (sociedades anónimas y por acciones).

Debido a que el Código Civil entró en vigencia casi una década antes que el Código de Comercio, reguló también a la Sociedad, tratándola como contrato, siguiendo el modelo francés. Así, el Código Civil define a la sociedad en su **Art. 2053** como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Acto seguido, el mismo artículo dispone que la sociedad es una persona jurídica, distinta a los socios individualmente considerados.

La disposición nos trae problemas a día de hoy, puesto que no queda claro si este contrato se celebraría entre dos personas para la creación de una tercera persona, o bien podría ser celebrado entre una sola persona y la persona jurídica que con el contrato crea.

A día de hoy, es posible la creación de sociedades por acciones por una sola persona, y además, las empresas pueden ser creadas por una persona, aunque no tienen en tal caso forma de sociedad.

El hecho de la creación de una nueva persona, distinta de los socios individualmente considerados es, a lo menos, interesante. Una sociedad legalmente constituida cumple con las características de una persona, teniendo por tanto todos los atributos de la personalidad con que cuentan las personas naturales, a excepción del estado civil.

Primero, respecto de la capacidad de goce, es decir, la aptitud para adquirir derechos y obligaciones, la persona jurídica actúa a través de su representante legal, ya que siendo un ente ficticio, lógicamente no puede actuar por cuenta propia.

En segundo lugar, respecto de la nacionalidad, nos interesa en la persona jurídica para la determinación de la legislación aplicable a la misma.

En tercer lugar, tenemos el nombre de la sociedad, el cual varía según el tipo de sociedad de que se trate, como estudiaremos más adelante.

En cuarto lugar, respecto del domicilio de la persona jurídica, cabe destacar que puede ser genérico, y es lo más común, puesto que la modificación del domicilio legal de una sociedad es sumamente costosa.

Por último, tenemos el patrimonio de la sociedad, entendido como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, avaluables en dinero. En el caso de una persona jurídica, se constituye por los aportes de los socios, lo cual es un elemento esencial de la sociedad, la cual no puede existir sin el aporte inicial de sus socios.

2. Clasificación de las Sociedades

A) Según su Giro u Objeto

En cuanto a su giro u objeto, las sociedades pueden clasificarse en **civiles** o **mercantiles**. **Art. 2059 CC:** “La sociedad puede ser civil o comercial.

Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.

La disposición citada cuenta con dos excepciones. En primer lugar, para las sociedades anónimas, que de acuerdo a la **Ley N°18.046** son siempre mercantiles, independiente de cuál sea su giro. En segundo lugar, tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada, que al igual que las sociedades anónimas, son siempre mercantiles, sin importar cuál sea su giro.

Las excepciones mencionadas, sin embargo, no son tan estrictas, puesto que en virtud de la aplicación del principio de la accesoriedad, estas sociedades podrían celebrar actos civiles, haciendo aplicable la legislación civil.

B) Según las Formalidades Requeridas para su Constitución

Según las formalidades requeridas para la constitución de la sociedad, ella puede ser **solemne o consensual**.

En Chile, las sociedades mercantiles son siempre solemnes, ya que siempre se requiere el cumplimiento de alguna solemnidad.

Por regla general, la sociedad mercantil, sin importar el tipo del cual sea, se forma y prueba por escritura pública. Esto con la excepción de la llamada sociedad por un día, que se forma por un acto de la autoridad administrativa.

C) Según sus Características

El **Art. 348** del Código de Comercio distingue, según las características de cada una, entre las sociedades **colectivas, por acciones y en comandita**, regulando cada una separadamente.

Lógicamente, existen otros tipos de sociedades mercantiles, tales como las de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas, pero con la particularidad de estar reguladas en leyes especiales.

D) Según la Responsabilidad de sus Socios

Atendiendo la responsabilidad que la ley asigna a los socios por las obligaciones sociales, la sociedad puede ser de responsabilidad limitada, ilimitada o mixta.

En las **Sociedades de Responsabilidad Limitada**, la sociedad responde con su propio patrimonio frente a terceros, de manera que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes, o en el caso de las sociedades anónimas y por acciones, hasta el monto de las acciones suscritas de cada socio.

En las **Sociedades de Responsabilidad Ilimitada**, en cambio, los socios responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales, sin derecho a excusión. Esto último, sin embargo, aplica para las sociedades colectivas mercantiles, ya que para las sociedades colectivas civiles, los socios responden ilimitadamente, aunque sólo a prorrata de sus aportes, sin perjuicio de un pacto expreso en contrario.

Por último, las **Sociedades de Responsabilidad Mixta** son aquellas en que sólo responden, por regla general, los socios gestores. Estas sociedades son las llamadas **en comandita**, y han caído en desuso con el tiempo.

E) Según el Interés Involucrado

Según el interés involucrado, podemos distinguir entre sociedades de personas, de capital o mixtas, dependiendo de la preponderancia que se le asigna a la cualidad e identidad de la persona del socio o al capital.

Las **sociedades de personas** son aquellas en que el elemento esencial que las distingue es la consideración a la persona de los socios, es decir, la existencia de un elemento subjetivo, que es la *affectio societatis*, la intención de querer celebrar el contrato de

sociedad con determinada persona. Lo importante no es el capital que aporte la persona, sino la persona misma.

La sociedad colectiva es la representación máxima de este tipo de sociedad, y ello se refleja en que cada socio puede administrar, de lo cual se desprende la confianza que existe entre los socios.

La desaparición de la *affectio societatis* puede incluso generar la disolución de la sociedad, lo cual refleja su calidad de elemento esencial, y de ello se desprende la importancia que tiene el elemento fiduciario en las sociedades de personas.

Las **sociedades de capital**, por otra parte, son representadas principalmente por la Sociedad Anónima, y más recientemente por la Sociedad por Acciones. Ya no importa la persona con tanta fuerza, sino que lo fundamental es el capital aportado por cada socio, y la persona que administrará tal capital.

En estas sociedades, la gran característica es la libre cesibilidad de las acciones, pudiendo un accionista salir de la sociedad en el momento que quiera.

Si la sociedad es cerrada, habrá que analizar la forma de cesibilidad de las acciones para cada sociedad.

También existen **sociedades mixtas**, en las cuales, por una parte, es importante el capital, pero por otra, es importante la persona que va a administrar ese capital.

3. Elementos Esenciales de Toda Sociedad

Toda sociedad debe cumplir con ciertos elementos esenciales, sin los cuales no tiene existencia ante el derecho.

A) Presencia de Dos o Más Socios

No puede haber sociedad sin al menos dos socios, salvo por la empresa individual de responsabilidad limitada, la cual es una modificación legal que vino a transparentar ciertos problemas que existían en las sociedades de personas.

Se discute en la actualidad si la sociedad por acciones es una excepción, ya que estas sociedades pueden ser constituidas por un solo accionista, siendo igualmente sociedad.

Pero esto se refiere sólo a la constitución de la sociedad, ya que por lo general en estas sociedades las acciones se venden rápidamente a terceros. Para el profesor no constituye una excepción, ya que es algo transitorio y no de la esencia de la sociedad el hecho de que haya sólo un socio fundador.

B) Aporte de los Socios

Según se desprende de la definición del **Art. 2053 CC** y de lo dispuesto en el **Art. 2055** del mismo código, la obligación de aportar constituye un elemento esencial del contrato de sociedad, y consiste, concretamente, en aquello que cada socio se obliga a llevar al patrimonio social para el cumplimiento del giro estipulado.

Este aporte puede consistir en dinero, industria o trabajo avaluable en dinero.

El **Art. 379 CdC** se refiere también a esto al tratar las sociedades colectivas, ya que los socios que han cumplido pueden excluir al que no cumpla, e incluso accionar judicialmente mediante un procedimiento ejecutivo para obligarlo a cumplir con el aporte. La norma se explica, sobre todo, cuando uno de los socios fallece y sus herederos, o algunos de ellos, no efectúan el aporte. En otro caso, ejercer la vía judicial contra un socio en una sociedad de personas significaría, en la práctica, la muerte de la sociedad.

C) Objeto de la Sociedad

Con el objeto de la sociedad nos referimos al acto o conjunto de actos que la sociedad realiza dentro de su giro, lo cual es una exteriorización de la voluntad de los socios.

Es un elemento esencial que los socios deben estipular en el estatuto, y que sólo puede alterarse mediante una modificación del mismo, lo cual representa una garantía de estabilidad no sólo para la sociedad misma, sino para los socios que consintieron en realizar un giro determinado.

Ahora bien, el hecho de que el estatuto designe un objeto social no implica que la sociedad tenga efectivamente una sola actividad. Lo importante es que el giro principal de la empresa esté determinado en los estatutos.

D) Participación en las Utilidades y Contribución en las Pérdidas

La definición de contrato de sociedad que nos da el Código Civil contempla la participación en las utilidades como un elemento esencial del contrato, y aunque no trata expresamente la contribución en las pérdidas de la misma manera, se entiende que tienen la misma calidad.

El beneficio que se reparten los socios debe necesariamente ser económico, por lo que no se considera un beneficio el puramente moral y no apreciable en dinero.

Ahora bien, entre los socios hay un contrato bilateral, que es el contrato de sociedad, pero el obligado a pagar estos dividendos es la sociedad, por lo que, a opinión del profesor, hay una segunda convención unilateral por la cual la sociedad se obliga a pagarle a los socios.

Ahora bien, los socios también deben contribuir en las pérdidas, por lo que si la sociedad tiene pérdidas, los socios tendrán que responder. Para ello, habrá que distinguir si la sociedad es de responsabilidad limitada o ilimitada. En el primer caso, los socios sólo responderán por el monto de sus aportes, y en el segundo caso, los socios tendrán que responder por el total de las pérdidas.

Sin embargo, si un socio garantiza las obligaciones contraídas por la sociedad, los terceros podrán dirigirse en su contra en cualquier caso.

Si nada se dice en la escritura social o en los estatutos, la participación en las utilidades y la contribución en las pérdidas es a prorrata del aporte de cada socio.

E) El Nombre de la Sociedad

El nombre de la sociedad, también llamado razón social, es el nombre bajo el cual la sociedad actúa en el tráfico jurídico, y cuyo uso legítimo la obliga frente a terceros.

Dependiendo del tipo de sociedad, el nombre o razón social tiene distintos requisitos, como estudiaremos en profundidad más adelante.

Unidad II – Las Sociedades de Personas

1. La Sociedad Colectiva

El **Art. 2061 CC** define a la sociedad colectiva como *“aquella en que todos los socios administran por sí, o por un mandatario elegido de común acuerdo”*.

Es una sociedad colectiva porque cada socio puede administrar, y ello se debe a la existencia de la *affectio societatis*, esencial para las sociedades de personas.

2. Formación y Prueba de la Sociedad Colectiva

Respecto de la formación de las sociedades colectivas, la materia está regulada por el **Art. 350 CdC**, que dispone: *“La sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública inscrita en los términos del artículo 354.*

La disolución de la sociedad que se efectúe antes de vencer el término estipulado, la prórroga de éste, el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de la razón social y en general toda reforma, ampliación o modificación del contrato, serán reducidos a escritura pública con las solemnidades indicadas en el inciso anterior.

No será necesario cumplir con dichas solemnidades cuando se trate de la simple prórroga de la sociedad que deba producirse de acuerdo con las estipulaciones que existan al respecto en el contrato social. En este caso la sociedad se entenderá prorrogada en conformidad a las estipulaciones de los socios, a menos que uno o varios de ellos expresen su voluntad de ponerle término en el plazo estipulado mediante una declaración hecha por escritura pública y de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción respectiva en el Registro de Comercio antes de la fecha fijada para la disolución”.

Así, la sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública, inscribiéndose la escritura en el registro del comercio que lleva el Conservador de Bienes Raíces respectivo, y publicándose en el Diario Oficial. Lógicamente, lo que se inscribe no es la totalidad del contrato, sino un extracto con las menciones mínimas que la ley requiere.

De la misma manera, la disolución de la sociedad que se efectúa antes del vencimiento del término estipulado, la prórroga del plazo, el cambio, retiro o muerte de un socio, la reforma de la razón social, y en general cualquier reforma, ampliación o modificación del contrato deben también constar por escritura pública, debiendo inscribirse y publicarse de la misma manera que en la constitución de la sociedad.

La única excepción a los trámites de escritura pública y su inscripción y publicación existe cuando se estipula una prórroga automática del plazo de duración del contrato salvo manifestación de voluntad de los socios.

Darle un plazo de vigencia a la sociedad puede ser conveniente cuando se trata de sociedades de personas, tales como las sociedades colectivas, ya que no se tiene total certeza del éxito del negocio, y por lo tanto, la existencia de un plazo puede ser ventajoso para los socios si dentro de cierto tiempo el negocio no ha prosperado.

En esta misma línea, el profesor considera recomendable estipular un plazo de tres a cinco años, renovable, tras el cual se producirá un punto de inflexión para la sociedad, tras el cual podría crecer, mantenerse en las mismas condiciones, o bien finalizar.

Dentro de estos tres a cinco años, ya se tienen varios ejercicios completos, por lo que puede evaluarse de forma precisa la forma en que funciona la sociedad y predecir el futuro de la misma y la conveniencia de mantenerla o ponerle fin.

En las sociedades de capital, por otra parte, lo mejor es poner un plazo indefinido, ya que al existir muchos más socios y estar focalizada en el capital, la existencia de un plazo

sería una limitación al hipotético éxito de la sociedad, que funcionaría como desincentivo para potenciales accionistas.

Entonces, la escritura pública es una solemnidad necesaria para la formación de la sociedad, a tal punto que si se firmara en un documento privado, el **Art. 351 CdC** dispone que este contrato no producirá otro efecto entre los socios que el de obligarlos a otorgar la escritura pública antes de que la sociedad dé principio a sus operaciones. Antes de ello puede existir un cuasicontrato de sociedad, o una sociedad de hecho, pero la sociedad como tal no existe.

Una escritura pública es un documento otorgado ante competente funcionario, dentro de sus potestades y con las solemnidades legales requeridas. Este funcionario puede ser un notario, o un oficial del registro civil en las comunas o agrupaciones de comunas donde no exista notario.

El notario público incorpora la escritura a su protocolo, dándole un folio, y queda en su poder durante un año, tras lo cual, para conseguir una copia, se debe acudir al archivo judicial.

Art. 1699 CC: *“Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario.*

Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública”.

El instrumento público constituye plena prueba respecto del hecho de haberse otorgado y de su fecha. Respecto de los hechos contenidos en él, sin embargo, sólo hace plena fe entre los declarantes.

Art. 1700 CC: *“El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes.*

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos por título universal o singular”.

En virtud del **Art. 353 CdC**, no se admite prueba alguna contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento del **Art. 350**, ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ella.

En teoría, cualquier prueba en contrario debería tenerse por no presentada, siguiendo el tenor literal del artículo, pero en la práctica, los tribunales suelen admitirlas, sin perjuicio de que posteriormente no suelen tener valor.

En la medida en que la escritura social esté bien otorgada, el instrumento público no admite prueba en contrario.

3. Menciones Mínimas de la Escritura de Sociedad Colectiva

Las menciones mínimas de la escritura social están reguladas en el **Art. 352 CdC**, que dispone las siguientes:

- **Nombres, Apellidos y Domicilios de los Socios**

Consiste básicamente en una individualización de los socios, lo cual es fundamental en la sociedad colectiva, ya que al tener como elemento esencial la *affectio societatis*, debe estar claramente determinada la identidad de cada uno de los socios.

- **Razón o Firma Social**
Consiste en el nombre de la sociedad, que va asociado con la importancia y prestigio que tenga la marca.
- **Socios Encargados de la Administración y Uso de la Razón Social**
Como dijimos anteriormente, y conforme al **Art. 2061 CC**, en las sociedades colectivas todos los socios pueden administrar y hacer uso de la razón social, pero puede estipularse en la escritura social algo distinto, como el nombramiento de un mandatario que estará encargado de la administración y uso de la razón social. Si nada se dice, no obstante, se entiende que cada uno de los socios podrá administrar y hacer uso de la razón social.
- **El Capital que Aportan los Socios**
Como mencionamos anteriormente, el aporte de los socios no debe necesariamente ser en dinero, pudiendo consistir en industria o trabajo avaluable en dinero.
Debe determinarse el capital que aporta cada socio, sin importar en qué consista, el valor que se le asigne a tal aporte, o bien la forma en que deba determinarse el valor de tal aporte.
- **Las Negociaciones sobre que deba versar el Giro de la Sociedad**
Nos referimos al objeto sobre el cual versará la sociedad, que puede ser uno sólo o bien múltiple.
- **La Parte de Beneficios o Pérdidas Asignados a cada Socio**
Se trata de la determinación de la participación en las utilidades y la contribución en las pérdidas que tendrá cada socio.
Como mencionamos anteriormente, no vale la repartición de beneficios puramente morales, debiendo ser apreciables en dinero.
En caso de no determinarse una manera específica de repartición o contribución, se entiende que se calculan a prorrata del aporte de cada socio.
- **La Época en que la Sociedad debe Principiar y Disolverse**
Puede establecerse una vigencia indefinida, pero como vimos anteriormente, es conveniente establecer un plazo de entre 3 y 5 años para las sociedades colectivas.
- **La Cantidad que puede tomar anualmente cada Socio para sus Gastos Particulares**
Esta materia está más regulada en las sociedades de capital, como en las Sociedades Anónimas, y debe estar determinado siempre.
- **La Forma en que se Verifica la Liquidación y División del Haber Social**
Lo normal es que se establezca que la división se efectúe de común acuerdo, o bien que se nombre un liquidador de manera previa.
Un liquidador debe determinar el activo y el pasivo, determinando la situación financiera de la sociedad para luego poder hacer la división del haber, y la forma en que ello se haga debe estar determinada en la escritura social.
Cabe destacar que la personalidad de la sociedad se mantiene hasta su completa disolución.

- **Determinación de la Resolución de las Diferencias entre los Socios**

Debe establecerse en la escritura social si las diferencias serán o no sometidas a la resolución de arbitradores, y en caso de que así se haga, la forma en que deba hacerse el nombramiento.

Cabe mencionar que todo conflicto entre los socios es materia de arbitraje forzoso, y en la escritura debe determinarse el tipo de arbitraje.

- **El Domicilio de la Sociedad**

Conforme al **Art. 134 COT**, es relevante la determinación del domicilio para saber qué juez será competente para conocer de cualquier disputa judicial.

- **Demás Pactos Acordados por los Socios**

Los socios pueden agregar cualquier pacto, pero no es recomendable alargar demasiado la escritura, que con todas las menciones mínimas ya es de gran extensión.

Cabe destacar, no obstante esto último, que hay una cláusula que se agrega siempre, aunque no tiene el carácter de mención mínima, y es la solución que debe darse cuando muere uno de los socios.

Por lo general, se entiende que los herederos representarán a la sociedad y deben actuar de consuno y a través de un representante, pero puede estipularse que no tengan facultades de administración y uso de la razón social, lo cual tiene sentido, debido al elemento de la *affectio societatis*.

4. Requisitos Esenciales de la Sociedad Colectiva

A) Presencia de Dos o Más Socios

Como hemos mencionado anteriormente, es de la esencia de todo contrato de sociedad que existan dos o más socios, y la ley exige como mención mínima del contrato que se individualice a cada uno de los socios, lo cual es fundamental por la *affectio societatis*, debiendo estar claramente establecida la identidad de cada uno de los socios.

En caso de existir un error en el nombre, cabe preguntarse si es que constituye un vicio del consentimiento. El **Art. 1057 CC** señala que el error en el nombre no vicia el consentimiento siempre y cuando se sepa cuál es la persona con la que se contrata.

A mayor abundamiento, la **Ley N°19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades** permite efectuar rectificaciones a las escrituras sociales, y señala que no es un vicio de nulidad que las escrituras contengan errores ortográficos o gramaticales.

B) La Obligación de Aportar

La obligación de efectuar un aporte que tienen los socios está consagrada en el **Art. 392 N°4 CdC**, en virtud del cual debe existir un aporte efectivo, que conforme al **Art. 376 CdC**, puede consistir en dinero, créditos, muebles, inmuebles, las mercedes, los privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en general, toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad.

El **Art. 375 CdC** señala que el fondo social se compone de los aportes que cada socio entrega o se obliga a entregar, y conforme al **Art. 378 CdC**, los socios deben entregar sus aportes en la época y forma estipuladas en el contrato.

El capital no constituye utilidad, y no puede ser retirado por los socios, ya que pasa a ser parte del patrimonio de la persona jurídica, que es un tercero distinto al socio que efectuó el aporte. Los acreedores personales del socio, por lo tanto, no pueden embargar el aporte introducido a la sociedad por el socio.

Cabe preguntarse si es que los derechos sociales, por otra parte, son embargables, lo cual ha sido objeto de discusión en la doctrina, y han existido diversas interpretaciones en jurisprudencia.

Alessandri y Somarriva rechazan esta posibilidad, puesto que tal embargo significaría la entrada de un nuevo socio a la sociedad, lo cual atenta contra la *affectio societatis*.

Por otro lado, Munita sostiene que sí se podrían embargar los derechos sociales, ya que no están incluidos por el **Art. 445 CPC** como bienes inembargables.

Sin embargo, aunque podría trabarse el embargo de los bienes sociales de inmediato, el pago o apremio sólo podría exigirse una vez disuelta la sociedad, por lo que no entra un nuevo socio y no se afecta la *affectio societatis*. El profesor concuerda con esta teoría.

En virtud del **Art. 379**, el retardo en la entrega del aporte, sea cual fuere su causa, autoriza a los demás socios a excluir al socio moroso de la sociedad, o bien a proceder ejecutivamente contra su persona y bienes para compelerle al cumplimiento de su obligación, ya que al constar en escritura pública, el contrato de sociedad constituye un título ejecutivo.

El socio moroso debe responder, en cualquier caso, de los daños y perjuicios causados por su tardanza a la sociedad.

Por último, y en virtud del **Art. 381 CdC**, los socios no pueden exigir la restitución de sus aportes antes de concluirse la liquidación de la sociedad, a menos que consistan en el usufructo de los objetos introducidos en el fondo común.

C) El Objeto de la Sociedad

Conforme al **Art. 352 N°5**, la escritura social debe contener una mención de las negociaciones sobre que versará el giro de la sociedad.

El giro puede consistir en cualquier actividad económica que no atente en contra de la moral, las buenas costumbres y el orden público, lo cual está consagrado en la Constitución.

D) Participación en las Utilidades y Contribución en la Pérdida

La definición de contrato de sociedad que nos da el Código Civil contempla la participación en las utilidades como un elemento esencial del contrato, y aunque no trata expresamente la contribución en las pérdidas de la misma manera, se entiende que tienen la misma calidad.

El beneficio que se reparten los socios debe necesariamente ser económico, por lo que no se considera un beneficio el puramente moral y no apreciable en dinero.

En caso de no determinarse una manera específica de repartición o contribución, se entiende que se calculan a prorrata del aporte de cada socio.

Cabe destacar que existe una excepción respecto del socio industrial, que es aquel cuyo aporte es en industria o trabajo. El **Art. 383** señala que en cuanto a las ganancias y pérdidas del socio industrial, se estará a lo que se hubiere estipulado en el contrato, y no habiendo estipulación, el socio industrial lleva en las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico, sin soportar parte alguna en las pérdidas.

E) La Razón Social

El **Art. 365 CdC** define la razón social de la sociedad colectiva como la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”.

Sólo los nombres de los socios colectivos pueden entrar en la composición de la razón social, lo cual se explica porque estamos hablando de una sociedad de personas. Si un socio muere o se separa de la sociedad, su nombre se suprime de la razón social.

El uso de la razón social después de disuelta la sociedad constituye delito de falsedad, y la inclusión del nombre de una persona extraña constituye delito de estafa.

Si alguien tolerara la inserción de su nombre en la razón social de una sociedad extraña, se hace responsable a favor de las personas que hubieren contratado con ella.

Los socios colectivos indicados en la escritura social son solidariamente responsables de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social, y tal solidaridad no puede ser derogada por pacto alguno entre los socios.

En cuanto al **uso de la razón social**, el **Art. 2061 CC** dispone que, en la sociedad colectiva, todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. No hay que confundir, sin embargo, la administración de la sociedad con el uso de la razón social, ya que son conceptos distintos, sin perjuicio de que la administración de la sociedad incluye el uso de la razón social, conforme al **Art. 393 CdC**.

El **Art. 371 CdC** señala que sólo pueden usar de la razón social el socio o socios a quienes se hubiere conferido tal facultad por la escritura respectiva. En caso de no existir una delegación expresa, todos los socios pueden usar de la firma social.

El uso de la razón social puede ser conferido a una persona extraña a la sociedad, conforme al **Art. 372 CdC**. Sin embargo, debe existir autorización de todos los socios para ello, a diferencia de lo que sucede con la administración de la sociedad, ya que cada socio puede delegar su administración a un tercero.

Si un socio no autorizado usare la firma social, la sociedad no es responsable del cumplimiento de las obligaciones que él hubiere suscrito, salvo si la obligación se hubiere convertido en provecho de la sociedad. En tal caso, la responsabilidad se limita a la cantidad concurrente con el beneficio reportado por la sociedad (**Art. 373 CdC**).

Por último, en virtud del **Art. 374 CdC**, la sociedad no es responsable de los documentos suscritos con la razón social cuando las obligaciones que los hubieren causado no le conciernan y el tercero los aceptare con conocimiento de tal circunstancia. La norma es sumamente discutida, dado que pareciera constituir una causal liberatoria de responsabilidad, pero sólo se libera de responsabilidad cuando el uso de la razón social se dio sin autorización de los socios.

5. Administración de la Sociedad Colectiva

A) Aspectos Generales

El **Art. 384 CdC** nos otorga la regla general en cuanto a la administración de las sociedades colectivas, al disponer que debe ajustarse a los pactos contenidos en la escritura social, y en lo no previsto, a las reglas expuestas en el Código de Comercio.

La administración de la sociedad colectiva corresponde de derecho a todos y cada uno de los socios, los cuales pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños.

Si el contrato social no designa a la persona del administrador, se entiende que los socios se confieren recíprocamente la facultad de administrar y la de obligar solidariamente la responsabilidad de todos, sin necesidad de su noticia y consentimiento. Se constituye así un mandato por el sólo ministerio de la ley, en virtud del cual cada uno de los socios puede ejecutar válidamente todos los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que la sociedad se hubiera propuesto.

B) Derecho de Oposición

Ahora bien, conforme al **Art. 388 CdC**, cada uno de los socios tiene derecho a oponerse a la consumación de los actos y contratos proyectados por otro, a no ser que se refieran a la mera conservación de las cosas comunes. Esto es lo que se llama el **Derecho de Oposición**, regulado entre los **Arts. 388-391**.

La oposición suspende provisoriamente la ejecución del acto o contrato proyectado hasta que la mayoría numérica de los socios califique su conveniencia o inconveniencia.

Ya que el **Art. 389** habla de mayoría numérica, se entiende que todos los socios tienen el mismo voto, y no hay un voto mayor a otro por participación. Esto se explica, además, porque es una sociedad de personas y no de capital, por lo que no es un factor a tener en cuenta el porcentaje de participación de cada socio para determinar el voto de cada uno. Esto puede solucionarse en la escritura social disponiendo la cantidad de votos con los que cuenta cada socio.

El acuerdo de la mayoría sólo obliga a la minoría cuando recae sobre actos de simple administración o sobre disposiciones contenidas en el círculo de las operaciones designadas en el contrato social.

Si no hay mayoría absoluta, los socios deben abstenerse de llevar a cabo el acto o contrato proyectado.

Si a pesar de la oposición se verifica el acto o contrato, es necesario distinguir si el tercero con quien se contrató estaba de buena o mala fe. Si estaba de buena fe, los socios quedan obligados solidariamente a cumplir el acto o contrato, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizados por el socio que lo ejecutó. Si el tercero estaba de mala fe, sin embargo, la sociedad no queda obligada al cumplimiento del acto o contrato (**Art. 391 CdC**).

Ahora bien, cabe preguntarse si los demás socios pueden demandar al que ejecutó el acto o contrato para la indemnización de perjuicios. Puede no existir un daño patrimonial efectivo, pero sí un daño moral. Sin embargo, si se demanda a un socio, se acaba la *affectio societatis*, y eso significaría la muerte de la sociedad colectiva.

Una mejor alternativa sería establecer sanciones en la escritura social para estos casos, como una multa para aquel que celebra un acto o contrato a pesar de la oposición de los demás socios.

Lógicamente, debe existir una buena razón para oponerse, y sólo accionar en contra del socio que ejecuta el acto si existe realmente un perjuicio económico, ya que si le genera un beneficio a la sociedad, sería ilógico demandar al socio que ejecuta el acto o contrato. Por ello, es un requisito procesal para demandar la indemnización de perjuicios que el tercero haya estado de buena fe.

Si el socio que se opone diera aviso al tercero de la oposición y el tercero celebrara igualmente el acto, es discutible si existe o no mala fe, pero para el profesor es suficiente para que la sociedad no tenga que responder por el acto o contrato.

Lógicamente este aviso debe probarse, y aunque pueda hacerse por testigos, es siempre fundamental que exista constancia escrita.

Se ha ido desarrollando en nuestro país, a raíz de la legislación norteamericana y lo sucedido con el Caso Chispas, una corriente tendiente a evitar abusos de socios que tienen una posición dominante respecto de otros socios. Desde tal punto surge el llamado **Deber de Lealtad** entre los socios, en virtud del cual no se puede abusar de una posición dominante, lo cual está incluso sancionado por ley.

Delegada la administración en uno o más socios, los demás quedan inhibidos de administrar, conforme al **Art. 392 CdC**.

Por esto es muy importante ser cuidadoso al momento de delegar la administración de la sociedad. Ya no hay derecho de oposición para los demás socios, porque no cuentan con facultades de administración. La única alternativa sería revocar el mandato, pero con las limitaciones que tiene la revocación del mandato mercantil.

Si en una sociedad colectiva se delegó la administración a un tercero y uno de los socios, que está inhibido de administrar, vende uno de los bienes de la sociedad, hablamos de venta de cosa ajena.

La sociedad puede ratificar el acto celebrado, lógicamente. La ley lo permite en miras a la conveniencia que puede significarle a la sociedad y para evitar conflictos entre los socios, ya que de otra forma habría que demandar, y ello significaría la desaparición de la *affectio societatis*.

C) El Administrador Delegado

1) Responsabilidad del Administrador Delegado

El administrador delegado actúa con las facultades designadas en su título, por lo que cualquier exceso en el ejercicio de sus facultades lo hace responsable ante la sociedad por cualquier perjuicio o daño causado (**Art. 394 CdC**).

Nuevamente decimos que debe existir un perjuicio material, ya que si se produjeron utilidades, no hay daños patrimoniales. Ahora, distinto es el tema respecto del daño moral, y se discute si una persona jurídica puede o no demandar el daño moral.

Históricamente, en jurisprudencia se ha entendido que no se puede y ello por el mismo concepto de daño moral. Si entendemos el daño moral como un perjuicio inmaterial causado en la psiquis de una persona, lógicamente no podemos decir que exista un daño moral en la persona jurídica, al ser un ente ficticio que no tiene psiquis. Una persona jurídica no puede sentir dolor, tristeza o sufrimiento, y en tal sentido no podría demandar el daño moral.

Sin embargo, podría fundarse el daño moral en el desprestigio causado a la sociedad, y ello se ha aceptado recientemente en jurisprudencia. No hablamos de lucro cesante, ya que este último se refiere a una ganancia esperada, y en este caso el descrédito o desprestigio va mucho más allá de negocios que se esperaba celebrar en un corto plazo. La indemnización al daño moral causado a las personas jurídicas sí tiene reconocimiento en nuestra jurisprudencia actual, siempre y cuando el daño moral se traduzca en un perjuicio económico.

No podemos dejar de tener en cuenta que las personas jurídicas tienen derecho a la honra, que es un derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas, tanto naturales como jurídicas.

2) Facultades del Administrador Delegado

Por regla general, el delegado tiene únicamente las facultades designadas en su título, y cualquier exceso cometido en el ejercicio de ellas lo hace responsable ante la sociedad por todo daño o perjuicio causado (**Art. 394 CdC**).

Conforme al **Art. 395 CdC**, los administradores delegados representan a la sociedad judicial y extrajudicialmente, pero si no están investidos de un poder especial, no pueden vender ni hipotecar los bienes muebles por naturaleza o destino, ni alterar su forma, ni transigir ni comprometer los negocios sociales, sea cual sea su naturaleza.

Teniendo el administrador delegado la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, cabe preguntarse si es válido notificar una demanda hacia la sociedad a uno de los socios que no es el administrador delegado.

Para el profesor, la demanda sí está emplazada, ya que por la naturaleza de la sociedad de personas, cada socio puede administrar por su cuenta, y puede por tanto representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente.

Sin embargo, esta administración delegada requiere un poder especial para vender o hipotecar bienes inmuebles por naturaleza o destino, o para alterar su forma, o transigir o comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza.

Esto se explica porque los bienes inmuebles tienen una importancia enorme para el giro comercial, al no descapitalizarse.

Ahora bien, no se necesita un poder especial para vender los inmuebles sociales, siempre que tal acto se halle comprendido en el número de las operaciones que constituyen el giro ordinario de la sociedad, ni para tomar en mutuo las cantidades estrictamente necesarias para poner en movimiento los negocios de su cargo, hacer las reparaciones indispensables en los inmuebles sociales, alzar las hipotecas que los graven o satisfacer otras necesidades urgentes.

Los administradores tienen la representación legal de la sociedad en juicio, sea como demandante o demandada (**Art. 398 CdC**).

De esta norma se discute si puede nombrarse un administrador que no sea abogado. Por lo general se entiende que sí, aunque debe nombrarse un abogado que represente a la sociedad en procedimientos en que sea necesaria la defensa letrada, lo cual no ocurre, por ejemplo, ante juzgados de policía local.

Nada obsta a que en un proceso judicial se otorgue la representación en juicio a un abogado, siendo una persona distinta al administrador de la sociedad, quien será quien delegue la representación.

Por último, cabe la posibilidad de que exista más de un delegado, caso en el cual debemos distinguir según cuántos sean, distinción que hace el **Art. 399 CdC**.

Habiendo dos administradores, que según su título deban obrar de consuno, la oposición de uno de ellos impide la consumación de los actos o contratos proyectados por el otro.

Si los administradores conjuntos fueran tres o más, deben obrar de acuerdo con el voto de la mayoría, y abstenerse de llevar a cabo los actos o contratos que no lo hubieren obtenido.

Si uno de los administradores ejecutara el acto aun ante la oposición de la mayoría, se siguen las mismas reglas que en el derecho de oposición que estudiamos anteriormente.

D) El Administrador Estatutario

Mientras que el administrador delegado es nombrado por medio de una escritura pública, el administrador estatutario es nombrado en la misma escritura social, y mientras que el delegado puede ser un tercero ajeno a la sociedad, el administrador estatutario es siempre uno de los socios. Además, las facultades de ambos no son las mismas.

Conforme al **Art. 400 CdC**, el administrador nombrado por una cláusula especial de la escritura social puede ejecutar, a pesar de la oposición de los demás socios excluidos de la administración, todos los actos y contratos a que se extienda su mandato, con tal que lo verifique sin fraude.

Sólo en el caso en que sus gestiones produzcan perjuicios manifiestos a la masa común, la mayoría de los socios pueden nombrar un coadministrador, o bien solicitar la disolución de la sociedad.

Lo más común es tener un administrador estatutario, y esto porque es una sociedad de personas, donde la *affectio societatis* es determinante.

En caso de fallecer el administrador estatutario, y conforme al **Art. 401**, la facultad de administrar no se transmite a sus herederos, aun si hubiera estipulado que la sociedad subsista con los herederos del difunto.

Finalmente, si al hacer el nombramiento del administrador, sea delegado o estatutario, los socios no determinan la extensión de los poderes conferidos, el administrador se considera como un simple mandatario, y no tiene más facultades que las necesarias para los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que ésta se hubiere propuesto.

6. Prohibiciones de los Socios en la Sociedad Colectiva

La ley establece ciertas prohibiciones a las que están sujetos los socios de una sociedad colectiva, las cuales derivan del principio de buena fe contractual que existe entre los socios. Podrían deducirse de este principio incluso sin necesidad de estar establecidas como prohibiciones en la ley, y ello porque más allá del contenido del contrato, los principios subyacentes son siempre los mismos, al ser una sociedad de personas. Un socio no puede ponerse jamás por encima de la sociedad o de los demás socios, y a ello apuntan todas estas prohibiciones.

El **Art. 404 CdC** se encarga de establecer las prohibiciones particulares a cada socio, las cuales son:

- **Extracción del Fondo Común (Art. 404 N°1)**

Los socios no pueden extraer del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares.

La mera extracción autoriza a los demás socios para obligar al infractor al reintegro, o bien para que los demás puedan extraer una cantidad proporcional al interés que cada uno tenga en la masa social.

Una de las menciones mínimas es la cantidad que pueden extraer los socios para sus gastos particulares, y extraer más dinero es en la práctica un hurto en contra de los demás socios, lo cual es especialmente grave en sociedades de personas.

- **Aplicar Fondos Comunes a Negocios Particulares (Art. 404 N°2)**

Los socios no pueden aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en éstos la firma social.

En caso de hacerlo, el socio infractor debe llevar a la masa común las ganancias y cargar él solo con las pérdidas del negocio en que invierta los fondos distraídos, sin perjuicio de restituirlos a la sociedad e indemnizar los daños causados.

- **Ceder su Interés en la Sociedad (Art. 404 N°3)**

Los Socios no pueden ceder su interés en la sociedad a cualquier título, ni hacerse sustituir en el desempeño de las funciones que le correspondan en la administración, lo cual se debe al elemento de la *affectio societatis*.

Los demás socios pueden autorizar la sustitución o cesión, pero si no hay previa autorización, la cesión o sustitución son nulas.

Cabe preguntarse si es válida una cesión o sustitución en los derechos sociales a otro socio cuando uno quiere retirarse.

El socio al que no se le ceden los derechos podría verse perjudicado, ya que, por ejemplo, si antes eran tres socios con un tercio de participación cada uno, ahora uno quedará con el doble de participación que el otro.

La jurisprudencia ha fallado que la prohibición del **Art. 404 N°3** no distingue si la cesión se hace a un tercero o a otro socio, por lo que esa cesión requiere la autorización de todos los socios.

Se puede estipular que en caso de que un socio ceda su interés en la sociedad, con la autorización de los otros socios, debe hacerlo previamente a uno u otro socio. La ley no prohíbe la libre cesión de los derechos, siempre y cuando la cesión sea autorizada por los socios.

- **Explotar por Cuenta Propia el Giro de la Sociedad (Art. 404 N°4)**

El socio no puede explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los socios operaciones particulares de cualquier especie cuando la sociedad no tuviere un género determinado de comercio.

Es una prohibición lógica, puesto que si un socio compete con la sociedad está faltando gravemente al deber de lealtad con los demás socios.

Los socios que contravengan a estas prohibiciones son obligados a llevar al acervo común las ganancias y a soportar individualmente las pérdidas resultantes.

Por otra parte, el **Art. 405** dispone que los socios no pueden negar la autorización solicitada por alguno de ellos para realizar una operación mercantil, salvo que acrediten que las operaciones proyectadas les generarán un perjuicio cierto y manifiesto.

7. Duración de la Sociedad Colectiva

Conforme al **Art. 352 N°7 CdC**, si nada se dice respecto de la duración de la sociedad, se entiende que el contrato es indefinido, y como consecuencia, se extenderá por la vida de todos los socios.

Lo que busca el legislador con esta norma supletoria es que la sociedad mantenga su existencia en el tiempo, protegiendo de tal forma la certeza o seguridad jurídica de los terceros que contratan con la sociedad.

Como mencionamos anteriormente, es aconsejable establecer una duración prorrogable de entre tres y cinco años, teniendo en consideración que los bancos otorgan créditos pagaderos en un mínimo de 36 meses.

Como mencionamos anteriormente, los socios pueden agregar cualquier pacto, pero no es recomendable alargar demasiado la escritura, que con todas las menciones mínimas ya es de gran extensión.

Es aconsejable dejar a salvo la posibilidad de hacer exigible a cada socio su responsabilidad, y no renunciar jamás a la posibilidad de demandar a un socio. Se podría decir que siendo una sociedad de personas, ejercer acciones en contra de un socio significaría la muerte de la sociedad, pero si un socio perjudica a la sociedad, ya no existe *affectio societatis*.

8. Obligación de Inscripción de la Sociedad Colectiva

Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, la sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública, la cual debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial.

Esto se da por razones de publicidad, dándole seguridad jurídica a los terceros que contratan con la sociedad. Cuando contrato con una sociedad debo saber con quién estoy contratando, quién tiene poderes de administración y quiénes son responsables, por ejemplo. Como abogados estamos obligados a revisar la vigencia de la sociedad.

Art. 354 CdC: *“Un extracto de la escritura social deberá inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad.*

El extracto contendrá las indicaciones expresadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7° del artículo 352, la fecha de las respectivas escrituras, y la indicación del nombre y domicilio del escribano que las hubiera otorgado.

La inscripción deberá hacerse antes de expirar los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura social”.

En resumen, los requisitos que debe cumplir el extracto son:

- Inscripción en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad;
- Ciertas menciones mínimas del contrato:
 - Nombres, apellidos y domicilios de los socios;
 - Razón o Firma Social;
 - Socios encargados de la Administración y del uso de la Razón Social;
 - Aporte de cada socio;
 - Giro de la Sociedad;
 - Época en que la sociedad debe principiar y disolverse.
- Fecha de las escrituras;
- Indicación del nombre y domicilio del escribano que otorga las escrituras;
- Inscripción antes de expirar los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura social.

El plazo de inscripción es de sesenta días contados desde la fecha de otorgamiento de la escritura, el cual es un plazo excesivo a juicio del profesor, más aún teniendo en consideración la ley de saneamiento, que permite corregir las inscripciones extemporáneas.

En esta materia el **Art. 355 A** nos da la regla general, al disponer que la omisión de la escritura pública de constitución o de modificación, o de su inscripción oportuna en el Registro de Comercio, produce nulidad absoluta entre los socios, con la salvedad de lo dispuesto en los **Arts. 356 Inc. 1° y 361 Inc. 1°**.

Conforme al **Art. 351 Inc. 1° CdC**, el contrato consignado en un documento privado no produce otro efecto entre los socios que el de obligarlos a otorgar la escritura pública antes que la sociedad inicie sus operaciones.

Luego, en virtud del **Art. 356**, la sociedad que no consta de escritura pública, o de instrumento reducido a escritura pública, o de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho, y no puede ser saneada.

Los efectos de la inscripción y publicación de una sociedad se retrotraen a la fecha de otorgamiento de la escritura, pero sin la inscripción y publicación, nadie contratará con la sociedad, ya que no hay certeza de su existencia, y es susceptible de ser declarada nula absolutamente.

Ahora bien, si se contrata con una sociedad que no se ha inscrito ni publicado, el tercero que hubiera contratado de buena fe con ella tiene acciones en su contra. Los socios tendrán que responder solidariamente frente a terceros de buena fe, sin poder oponer excepción de nulidad.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el **Art. 357 CdC**, la ejecución voluntaria del contrato de sociedad no purga la nulidad de que adolezca por incumplimiento de solemnidades legales, sin perjuicio de la posibilidad de ser saneado el vicio. El

saneamiento se permite con la **Ley N°19.499**, que permite el saneamiento de vicios de nulidad de sociedades.

La ley permite que pueda sanearse incluso la nulidad absoluta, como en el caso de la omisión de la inscripción y publicación del extracto de la escritura social, y ello para no afectar las relaciones entre los socios que están ejecutando el contrato de sociedad y para la protección de los terceros de buena fe.

El saneamiento se lleva a cabo mediante escritura de saneamiento, que es una escritura pública que debe ser publicada en el Diario Oficial y genera como efecto que se reconozca la vigencia de la sociedad.

Esto se permite, como ya dijimos, teniendo en cuenta la protección de terceros de buena fe, que en todo caso pueden ejercer acciones ante los socios aun cuando no se sanean estos vicios de nulidad.

Ahora bien, el tercero que contrata con una sociedad que no ha sido legalmente constituida no puede sustraerse, por tal motivo, del cumplimiento de sus obligaciones, tal y como dispone el **Art. 359 CdC**.

9. Modificación de la Sociedad Colectiva

Toda modificación de la sociedad, salvo la mera prórroga del plazo de vigencia, requiere de las mismas formalidades que su constitución, es decir, escritura pública inscrita en el Registro de Comercio y publicada en el Diario Oficial.

Conforme al **Art. 361 CdC**, la modificación cuyo extracto no ha sido oportunamente inscrito en el Registro de Comercio no produce efectos ni frente a los socios ni frente a terceros, salvo que haya un saneamiento en conformidad a la ley y con las restricciones que ésta impone. La privación de efectos opera de pleno derecho, sin perjuicio de la procedencia de una acción por enriquecimiento sin causa.

10. Disolución de la Sociedad Colectiva

Conforme a lo dispuesto en el **Art. 407 CdC**, la sociedad colectiva mercantil se disuelve por los modos que determina el Código Civil.

Debemos tener en cuenta lo dispuesto en el **Art. 70 del Código Tributario**, en virtud del cual no se autoriza la disolución de una sociedad sin un certificado del Servicio de Impuestos Internos, en el cual conste que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus tributos.

A) Causales de Disolución

En cuanto a las causales de disolución de la sociedad colectiva, podemos encontrarlas en los **Arts. 2098 y ss. del Código Civil**, y pasamos a analizarlas.

1) Expiración del Plazo o Cumplimiento de la Condición

Según dispone el **Art. 2098 CC**, la sociedad se disuelve por la expiración del plazo o por el evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin.

No obstante, puede prorrogarse la vigencia de la sociedad por el consentimiento unánime de los socios, y con las mismas formalidades que para la constitución.

Los codeudores de la sociedad no son responsables de los actos que inicie durante la prórroga si no hubieren accedido a ella.

2) Finalización del Negocio por el cual se constituyó la Sociedad

Conforme al **Art. 2099 CC**, la sociedad se disuelve por la finalización del negocio para el cual fue contraída.

Ahora bien, si se prefijó un día cierto para que la sociedad terminara y ese día llega antes de finalizarse el negocio, sin que se acuerde una prórroga, la sociedad se disuelve.

3) Insolvencia de la Sociedad

Conforme a la primera parte del **Art. 2100 CC**, la sociedad se disuelve por su insolvencia. Cabe destacar que la mayoría de las empresas que quiebran no lo hacen por insolvencia, sino por flujo de caja. En otras palabras, no quiebran porque no tengan la capacidad de generar negocios, sino por que no llevan sus negocios de forma ordenada.

Aún si en la sociedad no hay utilidades, los créditos deben pagarse igualmente, ya que aun sin tener flujo de caja, se tienen activos o cuentas por cobrar, por ejemplo.

Los acreedores pueden solicitar la liquidación forzada de la sociedad por el solo hecho del no pago de sus obligaciones mercantiles.

Se entiende por insolvencia un estado generalizado en virtud del cual se constata que los deudores no tienen capacidad alguna de pagar sus créditos, y si existen activos, no hay una incapacidad absoluta, y es por ello que decimos que en la mayoría de los casos las empresas no quiebran por insolvencia, sino por flujo de caja.

Ahora bien, si la sociedad está con problemas de flujo de caja y no puede pagar sus deudas de manera regular, se puede pedir la declaración judicial de insolvencia, ya que por mucho que sean conceptos distintos, los problemas de flujo de caja pueden llevar a la insolvencia. Una vez declarada la insolvencia de la sociedad, un **liquidador** asume la administración de la sociedad.

Ahora bien, si el socio administrador de la sociedad es declarado insolvente, queda inhibido de administrar los negocios sociales, pero no deja de ser socio, y el liquidador no pasará a administrar la sociedad, por cuanto no existe con él *affectio societatis*.

4) Incumplimiento de la Obligación de Aportar

Conforme al **Art. 2101 CC**, si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tienen derecho para dar la sociedad por disuelta.

Ya dijimos anteriormente que el aporte de los socios es un elemento esencial del contrato de sociedad, que no es válido, por lo tanto sin el aporte. Todo esto sin perjuicio de la posibilidad de estipular un aporte diferido o sujeto a plazo.

5) Pérdida de la Cosa Aportada

Según establece el **Art. 2100**, la sociedad se disuelve por la extinción de la cosa o cosas que forman su objeto total, y si la extinción es parcial, continúa la sociedad, salvo que los socios exijan su disolución si con la parte que resta no pudiese continuar útilmente.

El **Art. 2102** señala que si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste la sociedad aunque esa cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar útilmente.

Es importante recordar que las cosas perecen para su dueño, por lo que una vez efectuado el aporte, las cosas pasan a ser de la sociedad. Sin perjuicio de ello, a día de hoy es muy difícil que se aporten bienes distintos al capital o terrenos, por lo que esta causal de disolución va cayendo en desuso.

6) Muerte de uno de los Socios

En la medida en que no se haya estipulado la continuidad de la sociedad con los socios sobrevivientes, la muerte de uno de los socios deriva en la disolución de la sociedad.

Aun cuando no se haya estipulado tal cosa, se entiende continuar la sociedad mientras los demás socios no tengan noticia del fallecimiento. Incluso después de recibida la noticia,

las operaciones iniciadas por el difunto que no supongan una aptitud peculiar en éste deben llevarse a cabo.

Los herederos del socio difunto que no hayan de entrar en sociedad con los sobrevivientes sólo pueden reclamar lo que tocara al difunto según el estado de los negocios sociales al tiempo de saberse la muerte, y no participan de las ganancias o pérdidas posteriores sino en cuanto fueran consecuencia de las operaciones que al tiempo de saberse la muerte ya estaban iniciadas.

Si la sociedad continúa con los herederos del difunto, tienen derecho para entrar en ella todos ellos, salvo que sean incapaces, y aquí hay que tener en consideración que en materia mercantil hay normas especiales de capacidad, por lo que los menores adultos que actúan respecto de su peculio profesional pueden entrar a la sociedad.

Los que no tengan la libre administración de sus bienes concurren a los actos sociales por medio de sus representantes legales o por medio de quien tenga la administración de sus bienes.

Lógicamente, para entrar a la sociedad, los herederos deben haber aceptado la herencia.

7) Mutuo Consentimiento de los Socios

Como lógica consecuencia del principio de autonomía de la voluntad, los socios pueden poner fin a la sociedad por consentimiento unánime.

8) Renuncia de un Socio

La renuncia de un socio tiene como consecuencia la disolución de la sociedad, siempre y cuando ello no implique un perjuicio causado de mala fe a los socios.

Esto se explica porque la sociedad colectiva es una sociedad de personas, y la renuncia de un socio pone fin a la *affectio societatis* , pero si uno de los socios renuncia para hacer un negocio paralelo, existe mala fe, y en tal caso no se disuelve la sociedad.

Podría hacerse una cesión de derechos, pero ello es muy complejo en la práctica, por lo que la mejor alternativa para evitar la disolución de la sociedad es transformar la sociedad en una de capital.

B) Efectos de la Disolución de la Sociedad Colectiva

La disolución de la sociedad, al igual que la constitución y la modificación, debe hacerse necesariamente por escritura pública, la cual se anota marginalmente en la inscripción original. La anotación se efectúa para que los terceros contratantes sepan que se trata de una sociedad en disolución.

El efecto respecto de los socios es que deben proceder a la liquidación del acervo social, y sólo respecto de estos efectos se mantiene la personalidad jurídica, por lo que no podrá seguir contratando.

Por último, la disolución de la sociedad debe ser aprobada por el Servicio de Impuestos Internos.

11. Liquidación de la Sociedad Colectiva

Conforme al **Art. 408 CdC**, disuelta la sociedad, se procede a la liquidación por la persona que al efecto haya sido nombrada en la escritura social o en la disolución.

Como ya dijimos anteriormente, una de las menciones mínimas de la escritura del contrato de sociedad colectiva es la forma en que se verifica la liquidación y división del haber social.

Lo normal es que se establezca que la división se efectúe de común acuerdo, o bien que se nombre un liquidador de manera previa.

Si en la escritura social o en la de disolución se acuerda el nombramiento de un liquidador sin determinar la forma del nombramiento, éste se efectúa por unanimidad de los socios, y en caso de desacuerdo, por el juzgado de comercio (juzgados civiles).

El nombramiento puede recaer en uno de los socios o en un extraño, y sólo en caso de unanimidad, pueden encargarse de la liquidación todos los socios colectivamente.

La ley permite que sea un socio el encargado de la liquidación, pero permitir que eso pase en la práctica sería bastante insensato. Si se estableció previamente que un socio sería el liquidador y luego la sociedad se disuelve por su culpa, se puede pedir la nulidad de la cláusula que lo nombra como liquidador.

El liquidador es un verdadero mandatario de la sociedad, y como tal, debe conformarse escrupulosamente con las reglas establecidas en su título, y responde de los perjuicios resultantes de sus operaciones dolosas o culpables.

Responde hasta de la culpa leve, por lo que debe actuar como un buen padre de familia y sujetarse a las instrucciones e indicaciones fijadas en el título y que le den las partes.

Art. 413 CdC: *“Aparte de los deberes que su título imponga al liquidador, estará obligado:*

1°. A formar inventario, al tomar posesión de su cargo, de todas las existencias y deudas de cualquiera naturaleza que sean, de los libros, correspondencia y papeles de la sociedad;

2°. A continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución;

3°. A exigir la cuenta de su administración a los gerentes o cualquiera otro que haya manejado intereses de la sociedad;

4°. A liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con terceros y con cada uno de los socios;

5°. A cobrar los créditos activos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos;

6°. A vender las mercaderías y los muebles e inmuebles de la sociedad, aun cuando haya algún menor entre los socios, con tal que no sean destinados por éstos a ser divididos en especie;

7°. A presentar estados de la liquidación cuando los socios lo exijan;

8°. A rendir al fin de la liquidación una cuenta general de su administración.

Si el liquidador fuere el mismo gerente de la sociedad extinguida, deberá presentar en esa época la cuenta de su gestión”.

En cuanto a la rendición de cuentas, los socios pueden eximirlo de tal obligación, pero ello jamás debe hacerse.

Conforme al **Art. 418**, los socios pueden también hacer la liquidación por sí mismos, caso en el cual deben ajustarse a las mismas reglas recién estudiadas. Las decisiones se adoptan por mayoría, y cualquier diferencia es materia de arbitraje forzoso, ya que respecto de la liquidación siguen siendo socios.

Todas las acciones contra los socios no liquidadores, sus herederos o causahabientes prescriben en cuatro años contados desde el día en que se disuelva la sociedad, siempre que la escritura social haya fijado su duración, o la escritura de disolución haya sido inscrita legalmente.

Pasados los cuatro años, los socios no pueden ser obligados a declarar judicialmente acerca de la subsistencia de las deudas sociales.

Ahora bien, si uno de los socios declara voluntariamente sobre la subsistencia de la obligación transcurrido el plazo, se obliga personalmente a su cumplimiento.

La prescripción no tiene lugar cuando los socios verifican por sí mismos la liquidación o la sociedad tiene la calidad de deudora en un procedimiento concursal de liquidación.

Las acciones de los acreedores contra el socio o socios liquidadores, considerados en ésta última calidad, y las que tienen los socios entre sí, prescriben por el transcurso de los plazos que señala el Código Civil, es decir, tres años para la acción ejecutiva, cinco años para la acción ordinaria y diez años para la acción extraordinaria.

12. Sociedad de Responsabilidad Limitada

Salvo en materia de responsabilidad, todo lo dicho respecto de la sociedad colectiva es aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada.

Fue creada con la **Ley N°3.918** del año 1923, con el objeto de permitir que los socios sólo se hicieran responsables hasta el monto de sus aportes o lo que estipularan, ya que en la sociedad colectiva los socios responden solidaria e indefinidamente.

Art. 1° Ley N°3.918: *“Se autoriza el establecimiento de sociedades civiles y comerciales con responsabilidad limitada de los socios, distintas de las sociedades anónimas o en comandita”.*

Art. 2° Ley N°3.918: *“Las sociedades con responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales, se constituirán por escritura pública, que contendrá, además de las enunciaciones que expresa el artículo 352 del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a más de esto se indique.*

Estas sociedades no podrán tener por objeto negocios bancarios, y el número de sus socios no podrá exceder de cincuenta”.

Las menciones de la escritura son las mismas que en la sociedad colectiva, con la particularidad de que debe establecerse la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a más de esto se indique. Si no se establece, los socios van a responder solidaria e ilimitadamente, y por lo mismo, es recomendable reiterar este punto cada vez que se modifiquen las escrituras.

No pueden tener por objeto negocios bancarios, y esto porque los bancos e instituciones financieras deben constituirse como sociedades anónimas abiertas.

El límite de cincuenta socios fue establecido por el legislador por la consideración de que sería el límite dentro del cual sigue existiendo *affectio societatis*.

La razón social puede contener el nombre de uno o más socios, al igual que en la sociedad colectiva, pero también puede incluir una referencia al objeto de la sociedad, y además, debe terminar con la palabra *“limitada”*, sin lo cual los socios van a ser solidariamente responsables de las obligaciones sociales.

Puede usarse un nombre de fantasía, como hacen las Sociedades Anónimas, y esto porque, estando en el ámbito del Derecho Privado, podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Sin embargo, este nombre de fantasía sólo existirá para efectos publicitarios, y será la razón social la que esté establecida en los estatutos y que deba usarse para contratar.

Un extracto de la escritura social, o la modificación de la misma, deben inscribirse y publicarse en la misma forma y plazos que los de la sociedad colectiva. En caso de

saneamiento de un vicio, los efectos se retrotraen al momento en que se otorga la escritura pública, al igual que en la Sociedad Colectiva, con el objeto de proteger a terceros de buena fe y la relación entre los socios.

Los regímenes de administración de la Sociedad Colectiva aplican también aquí, y cabe preguntarse si es válido el emplazamiento a un socio que no sea administrador.

Conforme al **Art. 8° del Código de Procedimiento Civil**, el gerente o administrador de sociedades civiles o comerciales se entiende autorizado para litigar en su nombre, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actos constitutivos de la sociedad.

Al ser una sociedad de personas, y entendiéndose que, en principio, cada socio puede administrar por sí mismo la sociedad, la notificación a cualquiera de los socios es válida, por lo que existe emplazamiento y no se puede oponer la nulidad por falta del mismo. Si existe algún vicio en una actuación, pero no se provoca un perjuicio, tampoco podrá pedirse la nulidad.

En todo lo demás, conforme al **Art. 2° de la Ley N°3.918**, son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada todas las normas de la Sociedad Colectiva.

Es, por lejos, la sociedad de personas más utilizada, lo cual se explica, sobre todo, porque los socios no responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales.

13. Otras Especies de Asociación

Existen distintos tipos de pseudosociedades, como por ejemplo los consorcios o las que se forman por contratos innominados.

Los consorcios son una especie de pseudosociedad, actuaciones conjuntas consistentes en acuerdos para llevar a cabo negocios específicos.

Pueden darse, por ejemplo, en el caso en que una empresa constructora se asocia con una persona natural que tiene un terreno, constituyendo un proyecto común que les reportará beneficios a ambos, sin constituir una sociedad.

Otro tipo de pseudosociedad es el simple proyecto en común que tienen dos personas, sean naturales o jurídicas, que consta en un contrato innominado. En estos casos, si bien no existe sociedad, habiendo un contrato, puede exigirse la responsabilidad de los contratantes.

Cualquier otro tipo de sociedad de personas, o bien se enmarca dentro de la Sociedad Colectiva o de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, o bien no es sociedad. Esto demuestra que el sistema es bastante rígido.

La principal crítica que se hace a las sociedades de personas es la libertad en la cesión de derechos, ya que se requiere la unanimidad de los socios, limitando mucho la continuidad de la sociedad en caso de que un socio quiera retirarse.

Si un socio quisiera retirarse y los demás no le pagaran el porcentaje que le corresponde por su participación, no se configura lesión enorme, puesto que la figura sólo está contemplada para bienes inmuebles. Lo que sí puede hacerse es demandar por el abuso y los perjuicios producidos por el mismo.

Unidad III – Sociedades en Comandita

1. Aspectos Generales

En el ámbito histórico, las sociedades de personas se han ido quedando en el pasado, salvo por la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y ello porque el enfoque ha dejado de estar principalmente en la persona y ha pasado a estar en el capital.

En tal contexto, entró la Sociedad en Comandita, que como veremos, es una sociedad de una naturaleza más bien mixta, ya que, sin perjuicio de que en parte sigue existiendo consideración en la persona de los socios, está también mucho más enfocada en el capital que las demás sociedades que hemos visto hasta el momento.

El **Art. 470 CdC** define a la sociedad en comandita como aquella que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o por sus delegados y en su nombre particular.

Tenemos así dos especies de socios, siendo los primeros aquellos que efectúan el aporte a la sociedad, llamados **Socios Comanditarios**, y los segundos aquellos que administran la sociedad por sí o por medio de delegados y en su nombre particular, llamados **Socios Gestores**.

El socio gestor asume la representación de la sociedad, teniendo el uso de la razón social, y el socio comanditario, aunque aporta el capital, no está autorizado para participar de la administración. Esto último es más parecido a lo que sucede con las sociedades de capital, y es por ello que se habla de sociedad mixta.

Comparte las características de una sociedad de personas, pero el socio gestor necesita capital, independiente de la persona que aporte tal capital.

Lógicamente, el socio comanditario intentará que las facultades de los gestores estén lo más acotadas y delimitadas posibles, mientras que el gestor intentará tener las más amplias facultades, aunque finalmente, quien aporta el capital es quien manda.

Ahora bien, ha caído en completo desuso, debido principalmente a que los socios gestores responden solidaria e ilimitadamente de todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad, mientras que los socios comanditarios sólo responden hasta el monto de los aportes efectuados.

Conforme al **Art. 471 CdC**, las sociedades en comandita pueden ser simples o por acciones.

Según lo dispuesto en el **Art. 472 CdC**, la comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más socios comanditarios, o por éstos y los socios gestores a la vez.

Por su parte, tal y como establece el **Art. 473 CdC**, la comandita por acciones se constituye por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social.

2. Sociedad en Comandita Simple

La comandita simple se forma y prueba de la misma manera que la sociedad colectiva, y se rige según las mismas reglas, siempre y cuando tales reglas no se encuentren en oposición con la naturaleza jurídica de la sociedad en comandita.

El nombre de los socios comanditarios no figura en el extracto, pero si se incluye y éste lo tolera, se hace responsable en los mismos términos que los socios gestores.

La razón social debe comprender necesariamente el nombre del socio gestor o de uno o más de ellos si fueran varios. El nombre de un socio comanditario no se puede incluir en la razón social, y si un comanditario permite o tolera la inclusión de su nombre en la razón social, se constituye responsable de todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad en los mismos términos que el socio gestor, pero sin tener la posibilidad de actuar como gestor.

Respecto del aporte, el **Art. 478 CdC** dispone que el comanditario no puede llevar a la sociedad, por vía de aporte, su capacidad, crédito o industria personal. Sin embargo, su aporte puede consistir en la comunicación de un secreto de arte o ciencia, con tal que no lo aplique por sí mismo ni coopere diariamente a su aplicación.

También se permite como aporte el usufructo de un bien, caso en el cual el comanditario no soporta otra pérdida que la de los productos de la cosa que constituya su aporte, y en ningún caso está obligado a restituir las cantidades que a título de beneficios haya recibido de buena fe.

Ahora bien, el comanditario puede, sin perder el carácter de tal, asistir a las asambleas, teniendo en ellas un voto consultivo.

También puede ceder sus derechos en la sociedad, pero nunca la facultad de examinar los libros y papeles de la sociedad, mientras ésta no haya finalizado sus operaciones. Este es otro motivo por el que este tipo de sociedad ha caído en desuso, ya que al no poder transferir estas facultades, no es posible efectuar un *due diligence*, y nadie querría comprar esos derechos.

El socio comanditario no puede ejecutar actos de administración, aún en calidad de apoderado de los socios gestores, y en caso de violar esta prohibición, queda solidariamente responsable con los gestores de todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención.

Ahora bien, hay ciertos actos que no se consideran de administración, y que los socios comanditarios, por tanto, pueden ejecutar:

- Los contratos que por cuenta propia o ajena celebren con los socios gestores;
- El desempeño de una comisión en una plaza distinta de aquella en que se encuentre establecido el domicilio de la sociedad;
- El consejo, examen, inspección, vigilancia y demás actos interiores que pasan entre los socios, siempre que no traben la libre y espontánea acción de los gestores;
- Los actos que colectiva o individualmente ejecuten como comuneros después de la disolución de la sociedad.

Por último, habiendo uno o más socios comanditarios y muchos colectivos, sea que todos administren de consuno o que uno o más administren por todos, la sociedad va a ser, a la vez, comanditaria respecto de los socios comanditarios, y colectiva respecto de los socios colectivos. En caso de duda, la sociedad se reputa colectiva.

3. Sociedad en Comandita por Acciones

Si ya decíamos que la sociedad en comandita simple ha caído en desuso, la comandita por acciones está en un desuso aún mayor.

Es una sociedad enfocada plenamente en el capital, y dada la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios gestores, son mucho más preferibles otros modelos de sociedades de capital, como la Sociedad por Acciones.

Sigue siendo una sociedad en comandita, existiendo socios comanditarios y socios gestores, pero el capital está constituido por acciones o cupones de acciones, cuya propiedad pertenece a accionistas que no participan en la razón social.

El **Art. 492** deja en evidencia lo desactualizadas que se encuentran estas normas, y ello se explica en el desuso en que ha caído este tipo de sociedad. La norma en cuestión dispone que las sociedades en comandita no pueden dividir su capital en acciones o cupones de acción que bajen de diez centésimos de escudo, cuando aquél no exceda de cincuenta escudos.

Las sociedades en comandita no quedan definitivamente constituidas sino después de suscrito todo el capital y de haber entregado cada accionista al menos la cuarta parte del importe de sus acciones.

La suscripción y entrega deben ser comprobadas por la declaración del gerente en una escritura pública, y ésta debe acompañarse con la lista de suscriptores, un estado de las entregas y la escritura social.

En toda comandita por acciones se establece una junta de vigilancia, compuesta de al menos tres accionistas, y que se nombra por la asamblea general inmediatamente después de la constitución definitiva de la sociedad, y antes de toda operación social.

La junta debe examinar si la sociedad ha sido legalmente constituida, inspeccionar los libros, comprobar la existencia de los valores sociales en caja, en documentos o en cualquier otra forma, y presentar a la asamblea general, al final de cada año, una memoria acerca de los inventarios y de las proposiciones que haga el gerente para la distribución de los dividendos.

Esta junta de vigilancia tiene derecho de convocar la asamblea general y de provocar la disolución de la sociedad.

Cada uno de los miembros de la junta de vigilancia es solidariamente responsable con los gerentes cuando haya permitido a sabiendas que en los inventarios se cometan inexactitudes graves que perjudiquen a la sociedad o a terceros, o cuando con conocimiento de causa hubiera consentido en que se distribuyan dividendos no justificados por inventarios regulares y sinceros.

Unidad IV – La Sociedad Anónima

1. Aspectos Generales

A) Antecedentes

La Sociedad Anónima es la sociedad de capital por excelencia, ya que en virtud de ella se encuentran establecidos una enorme cantidad de comercios y empresas. Existen incluso ciertos negocios que sólo pueden ser ejercidos por Sociedades Anónimas, como sucede con los bancos o las AFP.

La regulación de las Sociedades Anónimas es extremadamente amplia, y está contenida mayoritariamente en la **Ley N°18.046**, publicada en 1981.

En noviembre del año 2018 se dictó la **Ley N°21.121**, que tipificó nuevos delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal, por lo que delitos como el cohecho dejan de estar regulados exclusivamente respecto de funcionarios públicos.

La extensa regulación de la Sociedad Anónima, no obstante, la ha hecho menos conveniente para empresas medianas y pequeñas, que suelen optar por el modelo de Sociedades por Acciones.

B) Concepto

El **Inc. 1° del Art. 1° de la Ley N°18.046** define la Sociedad Anónima como “*una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables*”.

De esta definición podemos extraer varios elementos distintivos.

En primer lugar, cuando habla de una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, queda en evidencia que el enfoque está en el capital y no en las personas, como sucede en la sociedad colectiva.

Luego, dispone que este fondo común es suministrado por accionistas, que además son responsables sólo por sus respectivos aportes. Queda claro de tal manera que es una sociedad de responsabilidad limitada, ya que los accionistas responden sólo hasta el monto de su participación.

Por último, tenemos una administración llevada a cabo por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. No son los accionistas quienes administran, como sucede en la sociedad colectiva, sino que se nombra un directorio que, además, es esencialmente revocable.

El **Inc. 2° del Art. 1°** nos dice que la sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil.

La interpretación de esta norma ha sido muy discutida, por cuanto muchos entienden que en su virtud, todo acto realizado por una sociedad anónima es mercantil, sin importar la naturaleza del acto mismo.

Sin embargo, esto no es así. La jurisprudencia ha entendido, siguiendo en este sentido a Puga, que por esta disposición no se entiende que todo acto realizado por la sociedad anónima sea mercantil, ya que la misma ley exige para la aplicación de las normas del Código de Comercio que estemos frente a un acto mercantil.

Por ello, lo que se entiende es que, al señalar la ley que la Sociedad Anónima es siempre mercantil, busca someterla como persona jurídica a las normas aplicables a los comerciantes en general, aunque sólo en lo concerniente a su actividad interna o intrasocietaria.

Esto tuvo mayor relevancia durante la vigencia de la antigua ley de quiebras, cuyo **Art. 41** disponía que el deudor que ejercía una actividad comercial debía solicitar la declaración de su quiebra antes de que transcurrieran quince días contados desde la fecha en que haya cesado en el pago de una obligación mercantil. Tal requisito sólo existía para el deudor que ejercía una actividad comercial, por lo que la discusión era de suma importancia para la declaración de quiebra. La nueva ley, sin embargo, eliminó este requisito.

C) Clasificación de las Sociedades Anónimas

El **Art. 2° de la Ley N°18.046** distingue entre sociedades anónimas abiertas, especiales y cerradas.

Las **sociedades anónimas abiertas** son aquellas que tienen quinientos o más accionistas, o en las cuales al menos un 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que directa o indirectamente excedan dicho porcentaje, o bien aquellas sociedades anónimas que inscriban voluntariamente sus acciones en el Registro de Valores.

Las **sociedades anónimas especiales** son aquellas indicadas en el **Título XIII de la Ley**, tales como las compañías de seguros y reaseguradoras, las sociedades anónimas administradoras de fondos mutuos o las bolsas de valores.

Toda otra sociedad anónima que no califique como abierta o especial se entiende **cerrada**.

Las primeras dos están bastante más reguladas, y el modelo cerrado se deja para empresas más pequeñas, sin perjuicio de que para ellas es más conveniente el modelo de Sociedad por Acciones.

Las sociedades anónimas cerradas pueden reglarse por las normas de las sociedades anónimas abiertas si así lo establecen sus estatutos, caso en el cual deben inscribir sus acciones en el Registro de Valores.

2. Constitución de la Sociedad Anónima

A) Formación, Existencia y Prueba

Art. 3° Inc. 1° Ley N°18.046: *“La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública inscrita y publicada en los términos del artículo 5°. El cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación producirá efectos retroactivos a la fecha de la escritura”.*

Al igual que la Sociedad Colectiva, la Sociedad Anónima se forma y prueba por escritura pública inscrita en el Registro de Comercio y publicada en el Diario Oficial. Ahora bien, tenemos una gran diferencia, que está en la palabra *existe*. Se le da una connotación no sólo al elemento formativo o constitutivo, sino a la vigencia de la sociedad.

El plazo para la inscripción de la escritura pública es de sesenta días contados desde su otorgamiento, y el cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación produce efectos retroactivos a la fecha de la escritura.

Las actas de las juntas de accionistas en que se acuerde modificar los estatutos sociales o disolver la sociedad, deben ser reducidas a escritura pública con las mismas solemnidades que en la constitución.

Es de suma importancia el **Inc. Final del Art. 3°**, en cuya virtud no se admite prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras que cumplan con las normas del mismo artículo, ni aun para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas.

B) Menciones Mínimas de la Escritura

La escritura pública, además, debe contener las menciones mínimas que establece el **Art. 4° de la Ley**:

- **Individualización de los Accionistas**

La escritura debe contener los nombres, profesión u oficio y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento, y el rol único tributario o documento de identidad, si debieran tenerlos.

Es una individualización de los accionistas, pero con la peculiaridad de que sean los que concurran a su otorgamiento. Esto porque lo importante no son las personas, sino el capital, por lo que no todos los accionistas deben concurrir al otorgamiento.

Además, es necesario el RUT o documento de identidad de estas personas. No es lo mismo, y la distinción se explica porque tanto personas naturales como jurídicas pueden constituir una sociedad anónima. Será el Rol Único Tributario para las empresas, y la cédula de identidad para las personas naturales.

Una sociedad puede crear otra sociedad sin que constituya un abuso de derecho, puesto que la ley no lo prohíbe, y en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíba.

- **Nombre y Domicilio de la Sociedad**

El **Art. 8°** señala que el nombre de la sociedad debe contener las palabras *sociedad anónima* o *S.A.*

Si el nombre de una sociedad fuera idéntico o semejante al de otra ya existente, esta última tiene derecho a demandar su modificación en juicio sumario.

Los nombres pueden repetirse, y ello se da mucho en la práctica, ya que nadie demanda en juicio sumario por el nombre de la sociedad.

Respecto del domicilio, el **Art. 5° A** dispone si en la escritura social se hubiera omitido el domicilio social, la sociedad se entiende domiciliada en el lugar de otorgamiento de la escritura.

- **Objeto u Objetos Específicos de la Sociedad**

La sociedad anónima puede tener un objeto singular o múltiple.

El **Art. 9°** señala que la sociedad puede tener por objeto u objetos cualquier actividad lucrativa que no sea contraria a la ley, a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado.

De esto se desprende que las sociedades anónimas no pueden constituirse sin fines de lucro, lo cual se explica, además porque las sociedades anónimas son siempre mercantiles, y la actividad comercial, por definición, está orientada a la generación de utilidades.

Si una sociedad anónima no tiene un giro lucrativo, a opinión del profesor, adolece de un vicio de nulidad, al no tener un objeto mercantil.

- **Duración de la Sociedad**

Si nada se dice, se entiende que la duración es indefinida.

La diferencia con la sociedad de personas está en la facilidad para el retiro de un accionista. La existencia de la sociedad anónima no depende de la permanencia de un accionista.

- **El Capital**

La escritura debe contener el capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido con indicación de sus series y preferencias si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal; la forma y plazos en que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero.

El capital es sumamente determinante, puesto que es lo relevante en este tipo de sociedades, y es por ello que la ley regula este numeral tan extensamente.

Nos dice además que hay distintos tipos de acciones, y la preferencia es de gran relevancia, dado que hay ciertas acciones que tienen prelación sobre otras, dando derechos políticos (voto) y económicos (que me paguen más o a sacar primero las utilidades).

La ley reconoce y establece que puede haber diferencias entre los accionistas.

El valor nominal se refiere al precio de la acción, y si no se establece, debe tasarse el valor de la acción.

Debe también indicarse la forma y plazo para la efectuación del aporte, y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero.

Se puede aportar bienes de cualquier naturaleza, sin existir más limitación que la indicación y valoración de tal aporte.

El **Art. 11** señala que el capital social se divide en acciones de igual valor. Si el capital se divide en acciones de distintas series, las acciones de una misma serie deben tener el mismo valor.

El capital inicial debe quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo igual o menos a tres años, y si ello no ocurre, al vencimiento del plazo el capital social se reduce al monto efectivamente suscrito y pagado.

No todos los aumentos de capital mantienen el porcentaje de participación, ya que si se aumenta el capital, para mantener la participación, los accionistas deben comprar más acciones.

Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas se reajustan en la misma proporción en que varía la unidad de fomento, conforme al **Art. 16**.

En todo caso, las acciones suscritas y no pagadas gozan de los mismos derechos sociales, salvo para la repartición de beneficios y devoluciones de capital, casos en los que sólo concurren en proporción a la parte pagada.

- **Organización y Modalidades de la Administración Social**

La escritura social debe indicar la organización y modalidades de la administración social, y de su fiscalización por los accionistas.

Aquí hay un tema sumamente relevante, ya que la ley regula la forma en que debe organizarse la administración social, debiendo existir un directorio, un gerente general, juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, el derecho a retiro, la prohibición a restricciones de participación, etc.

La organización establecida en los estatutos no puede ser inferior a los mínimos establecidos legalmente.

Agrega además la fiscalización de los accionistas, lo cual es un concepto bastante particular y de gran importancia en las Sociedades Anónimas.

La sociedad es administrada por un directorio esencialmente revocable, y este directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y todos sus poderes de actuación son controlados por los accionistas, quienes actuando en juntas fiscalizan las actuaciones del directorio.

- **Fecha en que debe Cerrarse el Ejercicio, Confeccionarse el Balance y Celebrarse la Junta Ordinaria de Accionistas**

La escritura debe contener la fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance, y la época en que debe celebrarse la junta ordinaria de accionistas.

Si nada se dice, se entiende que el ejercicio se cierra el 31 de diciembre y que la junta ordinaria de accionistas debe celebrarse dentro del primer cuatrimestre de cada año, en concordancia al **Art. 58 N°1 LSA**.

- **La Forma de Distribución de las Utilidades**

Dice la ley que queda abierta la posibilidad para establecer la forma de distribución de las utilidades, entendiéndose incluso que puede establecerse que por un año no se repartan utilidades.

Respecto de las Sociedades Anónimas Abiertas, salvo acuerdo unánime, deben repartir al menos un 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio (**Art. 79**).

Lo normal es que se repartan anualmente los beneficios de cada ejercicio.

- **La Forma en que debe Efectuarse la Liquidación**

En esto rige plenamente la autonomía de la voluntad, funcionando de manera muy similar a las sociedades de personas.

Una empresa operativa vale mucho más que una empresa cerrada. Por lo mismo, es más ventajoso fijar una continuidad de giro mientras se vende la sociedad.

- **El Arbitraje y su Naturaleza**

Sabemos de antemano que todo problema entre socios o accionistas se resuelve por arbitraje forzoso, y debe establecerse la naturaleza del arbitraje en tal caso.

Si nada se dice, se entiende que las diferencias son sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador.

- **Designación de un Directorio Provisorio**

En toda Sociedad Anónima debe designarse un Directorio Provisorio en su constitución.

Además, en las sociedades anónimas abiertas, deben designarse auditores externos o inspectores de cuentas, en su caso, que deben fiscalizar el primer ejercicio social.

Conforme al **Inc. 2° del Art. 5° A**, la omisión de cualquiera de estas designaciones faculta a la junta de accionistas para efectuarlas.

- **Demás Pactos que Acordaren las Partes**

Rige aquí plenamente la autonomía de la voluntad, por lo que los accionistas pueden incluir cualquier cosa que consideren relevante.

Dijimos respecto de las sociedades de personas que siempre hay que incluir lo que sucede cuando muere un socio. Aquí no, y si se muere un accionista, las acciones pasan a sus herederos sin que se disuelva la sociedad, y ello porque lo relevante es el capital, y no la *affectio societatis*.

C) Inscripción y Publicación del Extracto

Conforme a lo dispuesto en el **Art. 5° de la Ley**, un extracto de la escritura social, autorizado ante notario, debe inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial.

El plazo para efectuar la inscripción y publicación es de 60 días, contados desde la fecha de la escritura social.

Además, este extracto debe contener ciertas menciones mínimas:

- Nombre y Domicilio de los accionistas que concurren a su otorgamiento y el Rol Único Tributario o documento de identidad, si debieran tenerlo;
- Nombre, objeto(s), domicilio y duración de la sociedad;
- Capital y número de acciones en que se divide, con indicación de sus series y privilegios, si los hubiere, y si las acciones tienen o no valor nominal;
- Indicación del monto del capital suscrito y pagado, y el plazo para enterarlo, en su caso.

En cuanto a las modificaciones, el extracto de las mismas debe expresar la fecha de la escritura y el nombre y domicilio del notario ante el cual se otorgó. Sólo es necesario hacer referencia al contenido de la modificación cuando se hayan reformado algunas de las materias contenidas en las menciones mínimas del extracto de constitución.

D) Nulidad Absoluta por Vicios en la Constitución

Según dispone el **Art. 6°**, la Sociedad Anónima es nula absolutamente, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley, cuando:

- No sea constituida por escritura pública;
- En la escritura se omiten las menciones exigidas en los números 1, 2, 3 o 5 del **Art. 4°**;
- El extracto se inscribe o publica tardíamente;
- Se omite cualquiera de las exigencias del extracto.

Declarada la nulidad de la sociedad, ésta entra en liquidación. Sin embargo, la sociedad nula goza de personalidad jurídica y se liquida como Sociedad Anónima cuando consta de escritura pública o de un instrumento reducido a escritura pública o protocolizado.

A su vez, las reformas de los estatutos y el acuerdo de disolución de la sociedad adolecen de la misma nulidad cuando, aun siendo oportunamente inscritos y publicados, sus extractos carecen de alguna de las menciones mínimas que establece el **Art. 5° Inc. Final**. Sin embargo, estas reformas y acuerdo producen efectos frente a los accionistas y terceros mientras no sea declarada su nulidad, y la declaración de nulidad no produce efecto retroactivo, rigiendo sólo para las situaciones que ocurran a partir del momento en que quede ejecutoriada la resolución que la contenga, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley.

Se equipara a la omisión cualquier disconformidad esencial entre las escrituras y las inscripciones o publicaciones de sus respectivos extractos, y se entiende por disconformidad esencial aquella que induce a una errónea comprensión de la escritura extractada.

Los otorgantes del pacto que se declara nulo responden solidariamente frente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad.

En cualquier caso, no puede pedirse la nulidad de la sociedad o de una modificación en el estatuto social una vez que transcurren cuatro años desde la ocurrencia del vicio que la origina.

No obstante todo lo anterior, el **Art. 6° A** señala que la Sociedad Anónima que no consta en escritura pública, instrumento reducido a escritura pública o instrumento protocolizado es nula de pleno derecho e insaneable.

Ahora bien, si existiera de hecho, da lugar a una comunidad entre sus miembros. Las ganancias y pérdidas se reparten y soportan, y la restitución de los aportes se efectúa entre ellos con arreglo a lo pactado, y en subsidio, conforme a las reglas generales para las Sociedades Anónimas.

Los miembros de esta comunidad responden solidariamente frente a terceros con que hubieren contratado a nombre y en interés de ella, y no pueden oponer a los terceros la falta de los instrumentos de constitución. Los terceros pueden acreditar la existencia de hecho por cualquiera de los medios probatorios que reconoce el Código de Comercio, y la prueba se aprecia según las reglas de la sana crítica.

Por otro lado, la modificación cuyo extracto no es oportunamente inscrito y publicado no produce efectos ni frente a los accionistas ni frente a terceros, salvo el caso de saneamiento conforme a la ley y con las restricciones que ésta impone.

La privación de efectos opera de pleno derecho, sin perjuicio de la acción por enriquecimiento sin causa que proceda.

E) Publicidad de los Estatutos

Conforme al **Art. 7°**, las Sociedades Anónimas deben mantener en la sede principal y en las de sus agencias o sucursales, así como en su sitio web, en el caso de las Sociedades Anónimas Abiertas que dispongan de tales medios, a disposición de los accionistas, ejemplares actualizados de sus estatutos firmados por el gerente, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la escritura de constitución y la de sus modificaciones, en su caso, y de los datos referentes a sus legalizaciones.

Además, debe mantener una lista actualizada de los accionistas, con indicación del domicilio y número de acciones de cada uno.

Es de la responsabilidad del directorio la custodia de los libros y registros sociales, y que éstos sean llevados con la regularidad exigida por la ley y sus normas complementarias. El directorio puede delegar esta función, pero debe dejarse constancia de ello en actas. Los directores, el gerente y el liquidador o liquidadores, en su caso, son solidariamente responsables de los perjuicios que causen a accionistas y terceros en razón de la falta de fidelidad o vigencia de estos documentos, sin perjuicio de las sanciones administrativas que además pueda aplicar la Comisión para el Mercado Financiero.

3. El Capital Social, las Acciones y los Accionistas

A) Clasificación de las Acciones

En doctrina se aceptan distintas clasificaciones de las acciones, que pasamos a analizar:

- **Acciones Pagadas y Acciones Suscritas**

Las **acciones pagadas o definitivas** son aquellas cuyo valor ha sido íntegramente cubierto en cumplimiento al contrato de suscripción.

El capital inicial queda totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a tres años. Igual norma se aplica para las acciones de pago, éstas deben quedar emitirse, suscribirse y pagarse en un plazo no superior a tres años desde la fecha del acuerdo.

Las **acciones suscritas** son las que la sociedad emite y el accionista suscribe, esto es, se obliga a pagar el total de su valor dentro de un plazo, en virtud del contrato de suscripción.

- **Acciones Dinerarias o Representativas de Otros Bienes**

Las acciones pueden corresponder a aportes realizados en dinero o en otra clase de bienes. Las primeras, en silencio de los estatutos, deben enterarse en dinero efectivo. El valor de las segundas debe ser estimado por peritos, salvo acuerdo unánimes de las acciones emitidas.

- **Acciones de Pago y Acciones Liberadas de Pago**

Las **acciones de pago** son aquellas cuyo valor es pagado en dinero efectivo o en bienes que no consistan en dinero.

Las **acciones liberadas de pago**, o “crías”, son aquellas que emite una sociedad sin obligación de ser pagadas por los accionistas.

Las acciones liberadas de pago corresponden a las utilidades capitalizadas en virtud de un acuerdo de la junta extraordinaria de aumento de capital. Las acciones que se emiten se distribuyen entre los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha del reparto.

- **Acciones Ordinarias y Acciones Preferentes**

Las **acciones ordinarias o comunes** son aquellas que no contienen derechos especiales ni gozan de regímenes de favor.

Las **acciones preferentes o privilegiadas** son las que contienen derechos especiales sobre las acciones comunes, como preferencia en el reparto de utilidades, derecho a un interés acumulativo, derecho a restitución preferente en el caso de liquidación u otras preferencias que establezcan los estatutos.

Las preferencias deberán constar en los estatutos sociales y en los títulos de las acciones.

No pueden estipularse preferencias sin precisar el plazo de su vigencia.

No pueden estipularse preferencias que consistan en el otorgamiento de dividendos que provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus respectivas revalorizaciones.

No pueden establecerse series de acciones con derecho a voto múltiple.

Pueden existir acciones preferidas que carezcan de derecho a voto o que éste sea limitado, aunque adquieren pleno derecho a voto cuando la sociedad no haya cumplido con las preferencias.

- **Acciones de Capital y Acciones de Industria**

Las **acciones de capital** son aquellas que corresponden a un efectivo aporte en dinero o en bienes que no consistan en dinero.

Las **acciones de industria** corresponden a nuevas formas introducidas por el derecho y que tienden a que los trabajadores tengan participación efectiva en la empresa.

Nuestra legislación prohíbe las acciones de industria. Por lo tanto, hoy solo existen acciones de capital.

- **Acciones Con y Sin Valor Nominal**

Las **acciones con valor nominal** son aquellas que llevan en el título una referencia a su valor, una parte alícuota del capital social.

Los aumentos de capital deben traducirse en un aumento del valor nominal de las acciones, o bien, en una emisión de acciones liberadas de pago.

Las **acciones sin valor nominal** se caracterizan porque en el título respectivo no se señala valor alguno, sino que se expresa una cuota del capital social.

Estas acciones facilitan los aumentos de capital, la distribución de los fondos sociales, simplifican el cálculo de los votos en las asambleas generales y favorecen las amortizaciones.

Ahora bien, conforme al

B) Determinación del Capital

Según dispone el **Art. 10°**, el capital de la sociedad debe estar fijado de manera precisa en los estatutos de la misma, y sólo puede ser aumentado o disminuido por la reforma de ellos.

Sin embargo, el capital y el valor de las acciones se entiende modificado de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas aprueba el balance del ejercicio. El balance debe expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Estas revalorizaciones no se consideran aumentos de capital, por lo que no requieren escritura pública.

Al someter el balance del ejercicio a la consideración de la junta, el directorio debe previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio.

Luego, conforme al **Art. 11**, el capital social se divide en acciones de igual valor, y si el capital se divide en acciones de distintas series, las acciones de una misma serie deben tener igual valor.

El capital inicial debe quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a tres años, y si ello no ocurre, al vencimiento de tal plazo el capital social se reduce al monto efectivamente suscrito y pagado. Este plazo se cuenta desde que un accionista suscribe sus acciones, teniendo desde entonces tres años para pagarlas.

Las acciones son representativas de dinero, y de hecho, el **Art. 13** prohíbe la creación de acciones de industria y de organización.

C) Suscripción y Cesión de Acciones

La suscripción de acciones es un acto jurídico bilateral por el cual una persona se obliga a formar parte de una sociedad de capital, y a aportar una suma en principio igual al monto nominal del título. Este acto puede ser anterior o coetáneo con la constitución de la sociedad

Según dispone el **Art. 12 Inc. 1°**, las acciones son nominativas, y su suscripción debe constar por escrito en la forma determinada por el reglamento de la ley. La transferencia también se hace según el reglamento, el cual además determina las menciones que deben contener los títulos y la manera en que se reemplazan los títulos perdidos o extraviados.

Conforme al reglamento (**Art. 7°**), la Sociedad Anónima debe llevar un Registro de Accionistas en el que se anota, al menos, el nombre, domicilio y cédula nacional de identidad o rol único tributario de cada accionista, si lo tuviera, la serie, si la hubiere, y el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y, tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de pago de ellas.

Además, deben inscribirse en este Registro la constitución de gravámenes y derechos reales distintos al de dominio, y hacerse referencia a los pactos particulares relativos a la cesión de acciones. Si un accionista transfiere el todo o parte de sus acciones, debe anotarse esta circunstancia en el Registro.

Conforme al **Art. 38 del Reglamento**, toda cesión de acciones se celebra por instrumento privado firmado por el cedente y el cesionario ante notario público, o bien cada uno ante dos testigos mayores de edad, o ante un corredor de bolsa debidamente individualizados. También puede hacerse por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario, o de acuerdo a la Ley de Depósito y Custodia de Valores.

En cuanto a los derechos reales, pueden constituirse usufructos o prendas sobre las acciones, y en este último caso, hablamos de prenda sin desplazamiento.

En las Sociedades Anónimas Cerradas, no es necesario que se impriman láminas físicas de los títulos de acciones, pudiendo los estatutos disponer que se lleve únicamente un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, siempre que se resguarden debidamente los derechos de los accionistas (**Art. 14**).

Respecto de la cesión de acciones, la tradición se efectúa mediante la inscripción, pero siendo una tradición de bienes muebles, se perfecciona con la entrega, siendo la inscripción una solemnidad que existe para crear certeza de la tradición respecto de terceros. Ahora bien, si no se inscribe la tradición en el Registro de Accionistas, así como también la constitución de derechos reales, no se podrán hacer efectivos los derechos sobre esas acciones, sean políticos o económicos.

La adquisición de acciones de una sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales, de los acuerdos adoptados en juntas de accionistas y de la obligación de pagar las acciones en el caso que éstas no estén pagadas a la sociedad.

Es importante destacar que si una persona compra acciones suscritas que no están íntegramente pagadas, tendrá que pagarlas dentro del plazo de tres años desde que fueron suscritas, y no desde que se produjo la cesión de acciones.

Por otro lado, a la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, a menos que estos no se ajusten a las formalidades que hemos mencionado.

Si no se inscribieran, los directores y gerentes son solidariamente responsables, ya que están obligados a mantener fiel y públicamente expuesta toda la participación societaria y accionaria de la sociedad.

La cesión de las acciones produce efectos entre las partes desde su celebración, y respecto de la sociedad y de terceros, desde el momento de la inscripción del nuevo titular en el Registro de Accionistas.

Los interesados pueden acreditar que la sociedad ha tomado conocimiento de la cesión en mérito a una notificación practicada por un corredor de bolsa o notario público, quienes en el acto de la notificación deben entregar una copia del contrato de cesión y el título de las acciones, salvo que éste último estuviese en poder de la sociedad o no tuviera la obligación de imprimir láminas físicas de títulos.

Luego, según dispone el **Art. 44 del Reglamento**, en caso de transmisión o sucesión por causa de muerte, el heredero, asignatario o adjudicatario de las acciones puede inscribirlas a su nombre, previa exhibición a la sociedad del testamento inscrito, si lo hubiere, de la inscripción del auto de posesión efectiva de la herencia y del respectivo acto de adjudicación, en su caso.

A la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transmisión o adjudicación de las acciones y está obligada a inscribirlas, salvo que no se ajusten a las formalidades establecidas en el reglamento.

Art. 45 Reglamento: *“Las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos o legatarios no las registren a nombre de ellos dentro del plazo de cinco años contado desde el fallecimiento del causante, serán vendidas por la sociedad en la forma, plazo y condiciones siguientes:*

a) Transcurrido el plazo de cinco años antes señalado sin que se hubiere acreditado la existencia de herederos o legatarios interesados en las acciones, el gerente general de la sociedad procederá a citarlos mediante una publicación que hará en el Diario Oficial y otra en un diario distinto de circulación nacional. Entre ambas publicaciones no mediará un plazo superior a 10 días. El aviso de citación deberá contener los datos necesarios para individualizar al causante y a la sociedad.

b) Transcurrido el plazo de 60 días contado desde la última publicación sin que se hubieren presentado herederos o legatarios del titular de dichas acciones, el gerente general, actuando como representante legal de ellos, venderá las acciones en remate en una bolsa de valores.

c) Los dineros no cobrados por los herederos o legatarios a que se refieren las disposiciones anteriores y los provenientes de dividendos u otros beneficios en efectivo o de repartos por devolución de capital, que de conformidad a la ley pertenezcan a los Cuerpos de Bomberos de Chile, se pondrán por las sociedades a disposición de la Junta Nacional de dicha organización, quien prorrateará y procederá al pago de dichos dineros.

d) Las personas autorizadas por la ley para mantener acciones por cuenta de terceros, pero a nombre propio, y que tengan en sus registros de custodia acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos o legatarios no las registren a nombre de ellos dentro del plazo de cinco años contado desde el fallecimiento del causante, deberá informar de dicha situación a la sociedad con el objeto que ésta pueda dar cumplimiento a lo indicado en el presente artículo. En este último caso, la venta de las acciones se realizará por el custodio, previa instrucción de la sociedad”.

D) Libre Cesión de las Acciones

Según establece el **Art. 14 de la Ley**, los estatutos de las Sociedades Anónimas Abiertas no puede incluir limitaciones a la libre disposición de las acciones. A opinión del profesor, a pesar de que esta norma se refiere a las sociedades anónimas abiertas, debe entenderse que tiene aplicación general, puesto que hablamos de sociedades de capital, y es de la esencia de las mismas la libre cesibilidad de las acciones.

Los pactos particulares entre accionistas relativos a la cesión de acciones deben ser depositados en la compañía a disposición de los demás accionistas y terceros interesados, y debe hacerse referencia a ellos en el Registro de Accionistas. En cualquier caso, estos pactos no pueden afectar los derechos ni impedir el traspaso de las acciones.

Lo que la ley busca al establecer los pactos es que los propios accionistas puedan establecer nuevas formas de obtener las mayorías dentro de las sociedades.

En caso alguno puede impedirse la libre cesión, pero sí se puede regular la forma en que se lleve a cabo. Por ejemplo, si hay un pacto entre dos accionistas que tienen un 30% cada uno, van a tener ellos el control, y no el accionista que tenga el otro 40%.

Se discute si es que se puede establecer en una sociedad anónima cerrada un pacto de accionistas para que un accionista no pueda jamás vender sus acciones.

Atenta contra la libre circulación de los bienes, y además contra la esencia de lo que es una sociedad de capital. Si decimos que no se pueden vender estas acciones, hablamos de una sociedad de personas, y no de capital. El pacto puede surtir efectos, pero adolece de nulidad.

Ahora, sí podría establecerse que el accionista no venderá sus acciones por un plazo de cinco años, por ejemplo. Se puede porque no es una prohibición, sino una simple limitación de tiempo.

Por otro lado, podría acordarse que si uno de los pactantes se retira de la sociedad esté obligado a vender las acciones al accionista con el que suscribió el pacto, lo cual se permite por la existencia de derechos preferentes.

Los pactos de accionistas no pueden contradecir lo que se establezca en la escritura, y cualquier tipo de pacto que intente contradecir lo establecido en la escritura es nulo.

Tampoco puede vulnerar la esencia de una sociedad de capital. Pueden establecerse limitaciones, pero nunca prohibiciones absolutas para la libre cesibilidad de las acciones.

E) Pago de las Acciones

Conforme al **Art. 15 de la Ley**, las acciones pueden pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. En silencio de los estatutos, se entiende que el valor de las acciones de pago debe ser enterado en dinero efectivo, de manera que entren de forma inmediata a la caja social.

Si los directores o el gerente aceptaran una forma de pago de acciones distinta, se hacen solidariamente responsables del valor de colocación de las acciones pagadas en otra forma.

Salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas, todos los aportes no consistentes en dinero deben ser estimados por peritos, y en los casos de aumentos de capital, también es necesario que la junta de accionistas apruebe dichos aportes y estimaciones.

La falta del cumplimiento de esto último no puede hacerse valer pasados dos años contados desde la fecha de la escritura en la cual consta el respectivo aporte, y el cumplimiento de tales formalidades efectuado con posterioridad a la escritura de aporte sana la nulidad.

F) Tipos de Acciones

Según dispone el **Art. 20 de la Ley**, las acciones pueden ser **ordinarias** o **preferentes**.

Las preferencias deben constar en los estatutos sociales, y en los títulos de las acciones debe hacerse referencia a ellas.

No pueden estipularse preferencias sin determinar el plazo de su vigencia, ni estipular preferencias que consistan en el otorgamiento de dividendos que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus respectivas revalorizaciones.

Los estatutos de las sociedades anónimas abiertas pueden contener preferencias que otorguen a una serie de acciones preeminencia en el control de la sociedad por un plazo máximo de cinco años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas.

Luego, el **Art. 21** señala que cada accionista dispone de un voto por cada acción que posea o represente. Sin embargo, los estatutos pueden contemplar series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado. No pueden establecerse series de acciones con derecho a voto múltiple.

Las acciones sin derecho a voto o las con derecho a voto limitado, en aquellas materias que carezcan igualmente de derecho a voto, no se computan para el cálculo de los quórum de sesión o de votación en las juntas de accionistas.

Cuando existen series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado, tales acciones adquieren pleno derecho a voto cuando la sociedad no haya

cumplido con las preferencias otorgadas en favor de éstas, y conservan tal derecho mientras no se haya dado total cumplimiento a dichas preferencias.

Tal y como dispone el **Art. 22**, la adquisición de acciones de una sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales, de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas, y la de pagar las cuotas insolutas en el caso que las acciones adquiridas no estén pagadas en su totalidad.

G) Constitución de Gravámenes y Derechos Reales sobre las Acciones

Conforme al **Art. 23**, las acciones pueden prendarse o embargarse, pero el embargo y la prenda no son oponibles a la sociedad, a menos que se le hubiere notificado por ministro de fe, el cual debe inscribir el derecho real o gravamen en el Registro de Accionistas.

El embargo sobre acciones no priva a su dueño del pleno ejercicio de los derechos sociales, salvo el de la libre cesión de las acciones, que queda sujeta a las restricciones que establece la ley común.

En los casos de usufructo, las acciones se inscriben en el Registro de Accionistas a nombre del nudo propietario y del usufructuario, expresándose la existencia, modalidades y plazos del usufructo. Salvo disposición expresa en contrario de la ley o de la convención, el nudo propietario y el usufructuario deben actuar de consuno frente a la sociedad.

En caso de que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar un apoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad.

H) Aumentos de Capital

El **Art. 24 de la Ley** dispone que los acuerdos de las juntas de accionistas sobre aumentos de capital no pueden establecer un plazo superior a tres años, contado desde la fecha de los mismos, para emisión, suscripción y pago de las acciones respectivas, cualquiera sea la forma de su entero.

Vencido el plazo establecido por la junta de accionistas sin que se haya enterado el aumento de capital, el directorio debe proceder al cobro de los montos adeudados, si no hubiere entablado antes las acciones correspondientes, salvo que dicha junta lo hubiere autorizado por dos tercios de las acciones emitidas para abstenerse del cobro, caso en el cual el capital queda reducido a la cantidad efectivamente pagada.

Cada vez que se aumenta el capital o hay una toma de control hostil, se reduce la participación que tenían los accionistas, salvo que se haya establecido que los accionistas originales tengan preferencia para adquirir las nuevas acciones. Si entran nuevos accionistas, la participación de los antiguos disminuirá.

Conforme al **Art. 25**, las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad y de debentures convertibles en acciones de la sociedad emisora, o de cualquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre estas acciones, deben ser ofrecidas, al menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean. Las acciones liberadas emitidas por la sociedad se distribuyen de la misma forma. Se le otorga esta posibilidad a los accionistas para que su participación en la sociedad no se vea disminuida por el aumento de capital.

Este derecho es esencialmente renunciable y transferible, y debe ejercerse o transferirse dentro del plazo de treinta días contados desde que se publica la opción.

Por otro lado, la sociedad puede emitir acciones de pago, las cuales se ofrecen al precio que determine libremente la junta de accionistas.

El mayor valor que se obtenga entre el valor de venta y el valor nominal se capitaliza, y no puede ser repartido como dividendo.

I) Autoadquisición de Acciones

Puede ocurrir en ciertas situaciones que la sociedad deba adquirir sus propias acciones, lo cual está extensamente regulado, pues no es lo buscado por el legislador, y por lo mismo, sólo se permite en cinco casos expresamente establecidos en el **Art. 27 de la Ley**:

- **Ejercicio del Derecho de Retiro**

El derecho de retiro es aquel que tiene todo accionista para retirarse de la sociedad cuando está en contra de la aprobación por la junta de accionistas de ciertas materias contempladas en el **Art. 69**.

Cuando un accionista ejerce su derecho de retiro, la sociedad le paga el valor de sus acciones, por lo que es la propia sociedad la que adquiere las acciones.

- **Fusión de Sociedades**

La sociedad anónima puede adquirir y poseer acciones de su propia emisión cuando la adquisición resulta de la fusión con otra sociedad, que sea accionista de la sociedad absorbente.

- **Reforma de Estatutos de Disminución de Capital**

La sociedad anónima puede adquirir y poseer acciones de su propia emisión cuando la adquisición permite cumplir una reforma de estatutos de disminución de capital, cuando la cotización de las acciones en el mercado fuera inferior al valor de rescate que proporcionalmente corresponda pagar a los accionistas.

- **Acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas**

La sociedad anónima puede adquirir y poseer acciones de su propia emisión cuando la adquisición permita cumplir un acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas para la adquisición de acciones de su propia emisión, en las condiciones establecidas en los **Arts. 27-27 D**.

Hablamos de casos de tomas de control hostiles, donde los motivos pueden ser amplios, por lo que hay una regulación bastante extensa.

- **Caso del Art. 55 bis de la Ley General de Bancos**

La sociedad anónima puede adquirir y poseer acciones de su propia emisión cuando la adquisición se realice conforme al artículo citado, que se refiere al caso en que las empresas bancarias, previa autorización de la Comisión para el Mercado Financiero, emiten acciones preferentes o bonos sin plazo fijo de vencimiento, que pueden calificar como parte del patrimonio efectivo del banco emisor.

Mientras las acciones sean de propiedad de la sociedad, no se computan para la constitución del quórum en las asambleas de accionistas y no tienen derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital.

En los primeros dos casos mencionados, las acciones adquiridas deben enajenarse en una bolsa de valores dentro de plazo máximo de un año desde su adquisición, y de lo contrario, el capital se disminuye de pleno derecho.

Para la enajenación de acciones debe cumplirse con la oferta preferente a los accionistas del **Art. 25**.

J) Acuerdos de Reducción de Capital

Según lo dispuesto en el **Art. 28**, todo acuerdo de reducción de capital debe ser aprobado por dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto, y no puede procederse al reparto o devolución del capital o a la adquisición de acciones con que dicha disminución pretenda llevarse a cabo, sino transcurridos treinta días desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto de la respectiva modificación.

Dentro de los diez días siguientes a la publicación, debe además publicarse un aviso destacado en un diario de circulación nacional y en el sitio web de las sociedades anónimas abiertas que dispongan de tales medios, en el que se informe al público del hecho de la disminución de capital y de su monto.

Por otro lado, y conforme al **Art. 29**, en caso de que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, los créditos de los acreedores sociales, cualquiera sea la clase a que pertenezcan, prevalecen sobre los que posean los accionistas en razón de una disminución de capital.

Este orden de pago se estableció porque anteriormente, muchas empresas reducían su capital accionario y quedaban debiendo dinero al controlador, el cual establecía una prenda sobre el activo para que se le pagara primero en caso de quiebra, y dejando sin nada a los acreedores de la sociedad.

En relación con esto último, el **Art. 30** dispone que los accionistas deben ejercer sus derechos sociales respetando los de la sociedad y los de los demás accionistas. Esta norma deriva del principio de buena fe, e incluso podría entenderse que su inclusión es innecesaria.

Cabe ponerse en el caso en que un accionista demande a otro accionista, ya que dependiendo del caso, la demanda será por responsabilidad contractual o extracontractual, y no se puede demandar por ambas.

Se entiende que el contrato existe entre los accionistas con la sociedad, y no entre sí, por lo que la demanda de un accionista a otro sería por responsabilidad extracontractual, salvo que exista un pacto de accionistas, caso en el cual hablamos de responsabilidad contractual.

Si se quiere demandar tanto a un accionista como a la sociedad, no podrían interponerse ambas demandas conjuntamente, ya que son dos tipos distintos de responsabilidad, por lo que habría que interponer una demanda en subsidio de la otra.

4. Administración de las Sociedades Anónimas

La ley establece tres órganos para la administración de la sociedad, que son el directorio, los inspectores de cuenta o auditores externos y las juntas de accionistas, que pueden ser ordinarias o extraordinarias.

A) El Directorio

1) Aspectos Generales

Conforme al **Art. 31**, la administración de la sociedad anónima es ejercida por un directorio elegido por la junta de accionistas.

Los estatutos de las sociedades anónimas deben establecer un número invariable de directores, y la renovación del directorio es total y se efectúa al final de su período, el cual no puede exceder de tres años.

Los directores pueden ser reelectos indefinidamente en sus funciones. A falta de disposición expresa en los estatutos, se entiende que el directorio se renueva cada año.

El directorio de las sociedad anónimas cerradas no puede estar integrado por menos de tres directores, y el de las sociedades anónimas abiertas por menos de cinco directores, y si en los estatutos nada se dice, tal será la composición del directorio.

Se establece un número impar para que no existan empates en las tomas de decisiones.

Sin perjuicio de todo esto, si es que la sociedad anónima abierta debe designar al menos un director independiente y constituir un comité de directores conforme al **Art. 50 bis**, el mínimo de directores es siete.

Es de suma importancia tener en cuenta que el directorio es esencialmente revocable, y respecto de esto, el **Art. 38** dispone que el directorio sólo puede ser revocado en su totalidad por la junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, no procediendo en consecuencia la revocación individual o colectiva de uno o más de sus miembros.

Esto es así porque de lo contrario se volvería arbitrario, y las revocaciones individuales estarían completamente a disposición del controlador.

En cuanto a la remuneración, a esta materia se refiere el **Art. 33**, conforme al cual los estatutos deben determinar si los directores serán o no remunerados por sus funciones, y en caso de serlo, la cuantía de las remuneraciones se fija anualmente por la junta ordinaria de accionistas.

2) Prohibiciones para ser Director

Conforme al **Art. 35**, no pueden ser directores de una sociedad anónima:

- **Los Menores de Edad**

Aquí se genera un problema, ya que en materia mercantil, los menores de edad son capaces. Se entiende que prima la norma de la ley de sociedades anónimas, por aplicación del principio de especialidad, además de que ser director de una sociedad no es en sí un acto de comercio.

- **Personas Afectadas por la Revocación a que se Refiere el Art. 77**

Lo que establece el **Art. 77** es que cuando la junta de accionistas rechaza dos balances sometidos a su aprobación, se entiende revocado el directorio, y los directores que hubieren aprobado el balance que motivó su revocación quedan inhabilitados para ser reelegidos por el período completo siguiente.

- **Personas Condenadas por Delitos que Merezcan Pena Aflictiva, Inhabilitación Perpetua para Desempeñar Cargos Públicos y Deudores en Procedimientos Concursales de Liquidación**

No pueden ser directores las personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, y aquellos que tengan la calidad de deudor en procedimientos concursales de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales, o que hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

La persona que es deudora en un procedimiento de liquidación concursal está inhibida de administrar toda clase de bienes, por lo que es lógico que no puedan ejercer como directores.

- **Funcionarios Públicos en Entidades donde ejercen Funciones de Control**

No pueden ser directores los funcionarios fiscales, semifiscales, de empresas u organismos del Estado y de empresas de administración autónoma en las que el

Estado efectúe aportes o tenga representantes en su administración, en relación a las entidades sobre las cuales dichos funcionarios ejercen, directamente y de acuerdo con la ley, funciones de fiscalización o control.

Las personas que adquieran la calidad de funcionarios en los organismos o empresas públicas indicadas, cesan automáticamente en el cargo de director de una entidad fiscalizada o controlada.

Se busca con esto cumplir con ciertos estándares de transparencia y probidad, evitando posibles conflictos de interés.

Por otro lado, el **Art. 36** incluye ciertas **inhabilidades especiales** para ser director:

- Senadores, Diputados y Alcaldes;
- Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales y Embajadores, Jefes de Servicio y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos, con excepción de los cargos de director de las sociedades anónimas abiertas en las que el Estado, según la ley, deba tener representantes en su administración, o sea accionista mayoritario, directa o indirectamente a través de organismos de administración autónoma, empresas fiscales, semifiscales, de administración autónoma, o aquellas en que el Estado sea accionista mayoritario;
- Funcionarios de las superintendencias que supervisen a la sociedad respectiva o a una o más de las sociedades del grupo empresarial a que pertenece;
- Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, así como sus directores, gerentes ejecutivos principales y administradores. Esta restricción no aplica en las Bolsas de Valores.

3) Funciones del Director

Las funciones del director de una sociedad anónima no son delegables, y se ejercen colectivamente, en sala legalmente constituida.

Esto no obsta a que se puedan nombrar directores suplentes, lo cual permite expresamente el **Art. 32**.

Cada director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el gerente o el que haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa. Este derecho debe ser ejercido de manera de no afectar la gestión social.

Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes, no pudiendo faltar a éstos y a aquélla a pretexto de defender los intereses de quienes los eligieron.

Los gastos del directorio deben ser presentados en la memoria social, agrupados por ítem relevantes, e informados en la junta ordinaria de accionistas.

Sin perjuicio de esto, en las sociedades anónimas cerradas se puede prescindir de los acuerdos de directorio siempre que la unanimidad de sus miembros ejecute directamente el acto o contrato y que éstos se formalicen mediante escritura pública.

4) Facultades del Directorio

Conforme al **Art. 40**, el directorio de una sociedad la representa judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo cual no está obligado a acreditar frente a terceros.

Además, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, incluso para actos en que la ley exige tal poder.

Esto no obsta a la representación judicial que le compete al gerente, conforme al **Art. 49**.

El directorio puede delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Esto se hace generalmente para delegar facultades de representación en abogados para la comparecencia en juicio. El accionista mayoritario, por mucho control que tenga, no administra la sociedad. De hecho, un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel señaló que: *“el solo hecho de ser accionista mayoritario de una sociedad anónima no otorga a quien tenga esa calidad la que corresponde al directorio. Es más, no se permite siquiera a los directores de una sociedad anónima actuar a pretexto de defender los intereses de quienes los eligieron”*.

En cuanto a la **responsabilidad de los directores**, el **Art. 41** dispone que deben emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y responden solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables.

Así, responden hasta de la culpa leve, pero además solidariamente junto con todo el directorio, sin perjuicio de la posibilidad de que exista responsabilidad penal.

A esto se suma lo señalado en la **Ley N°21.121**, que estableció nuevos delitos, incluida la administración desleal, que es un tipo penal doloso y de términos bastante amplios. Se pueden dirigir querellas por administración desleal contra los directores.

Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de accionistas que pretenda liberar o limitar la responsabilidad de los directores.

La aprobación otorgada por la junta de accionistas a la memoria y balance presentados por el directorio o a cualquier otra cuenta o información general no libera a los directores de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados, ni la aprobación específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad cuando se hubieran celebrado o ejecutado con culpa leve, grave o dolo.

5) Prohibiciones de los Directores

Conforme al **Art. 42**, los directores no pueden:

- Proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social;
- Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los gerentes, administradores o ejecutivos principales en la gestión de la empresa;
- Inducir a los gerentes, administradores, ejecutivos principales y dependientes, o a los inspectores de cuentas o auditores externos y a las clasificadoras de riesgo, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas y ocultar información;
- Presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles informaciones esenciales;
- Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio, de sus parientes, representados o sociedades a que se refiere el **Art. 44 Inc. 2°**, los bienes, servicios o créditos de la sociedad, sin previa autorización del directorio otorgada en conformidad a la ley;
- Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, con perjuicio para la sociedad, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo;

- En general, practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.

Los beneficios percibidos por los infractores por la realización de lo dispuesto en los tres últimos casos pertenecen a la sociedad, la que además debe ser indemnizada por cualquier otro perjuicio. Esto no obsta a las sanciones que la Comisión para el Mercado Financiero pueda aplicar en el caso de sociedades sometidas a su control.

Los directores deben ejercer sus funciones de buena fe, y sin afectar los derechos sociales, ni menos los derechos de los accionistas. En doctrina se plantea que los directores deben actuar bajo dos principios, que son los deberes de lealtad y preocupación, el primero frente a la sociedad, y el segundo frente a los accionistas.

6) Deber de Reserva de los Directores

El **Art. 43** establece el deber de reserva que tienen los directores, al disponer que los directores están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por la compañía.

En el caso de las sociedades anónimas abiertas, se entiende que se ha producido dicha divulgación cuando la información se da a conocer mediante los sistemas de información al mercado previstos por la Comisión para el Mercado Financiero.

No rige esta obligación cuando la reserva lesione el interés social o se refiera a hechos u omisiones constitutivas de infracción de los estatutos sociales, de las leyes o de la normativa dictada por la Comisión para el Mercado Financiero en el ejercicio de sus atribuciones.

El deber de reserva tiene estricta relación con la no alteración de las condiciones del mercado, ya que estaría entrando información confidencial.

7) Conflictos de Interés

Una sociedad anónima cerrada sólo puede celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés, por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas previamente por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo que los estatutos autoricen la realización de tales operaciones sin sujeción a las condiciones de equidad mencionadas.

El directorio debe pronunciarse con la abstención del director con interés. En el acta de la sesión de directorio correspondiente, debe dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos, y tales acuerdos son informados en la próxima junta de accionistas por el que la presida, debiendo mencionarse esta materia en su citación.

Se entiende que existe interés de un director en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir:

- Él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad;
- Las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital;
- Las sociedades o empresas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas sea director o dueño, directo o indirecto, del 10% o más de su capital;

- El controlador de la sociedad o sus personas relacionadas, si el director no hubiera resultado electo sin los votos de aquél o aquéllos.

Se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 UF y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 UF.

La infracción a este artículo no afecta la validez de la operación y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, otorga a la sociedad, a los accionistas y a los terceros interesados, el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados.

En caso de demandarse los perjuicios, corresponde a la parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la sociedad que justifican su realización.

Además, es plenamente aplicable la figura penal de administración desleal.

8) Presunciones de Culpabilidad del Directorio

Según lo dispuesto en el **Art. 45**, se presume la culpabilidad de los directores, respondiendo en consecuencia solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad, accionistas o terceros, en los siguientes casos:

- Si la sociedad no lleva sus libros o registros;
- Si se reparten dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas, respecto de los directores que concurren al acuerdo respectivo;
- Si la sociedad oculta sus bienes, reconoce deudas supuestas o simula enajenaciones;
- Cuando uno o más directores se benefician de forma indebida, directamente o a través de otra persona natural o jurídica de un negocio social que, a su vez, irroge perjuicio a la sociedad.

La demanda a un director es de responsabilidad contractual, puesto que se le dotó de facultades de administración mediante los estatutos.

9) Reuniones de los Directores

Conforme al **Art. 47**, las reuniones del directorio se constituyen con la mayoría absoluta del número de directores establecidos en los estatutos, y los acuerdos se adoptan por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate, y salvo que los estatutos dispongan otra cosa, decide el voto del que preside la reunión. Los estatutos pueden establecer quórums mayores.

Se entiende que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Comisión para el Mercado Financiero.

Las deliberaciones y acuerdos del directorio se escrituran en un libro de actas por cualquier medio, siempre que éste ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que debe ser firmada por los directores que concurren a la sesión.

Desde el momento de su firma, el acta se entiende aprobada, y desde esa fecha pueden llevarse a efecto los acuerdos referidos en ella. El director que quiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio, debe hacer constar en el acta su oposición, debiendo dar cuenta de ello en la próxima junta ordinaria de accionistas por el que presida.

10) Gerentes

El directorio puede delegar sus funciones en un gerente general, e incluso, la ley exige que el directorio actúe representado por un gerente general.

Según dispone el **Art. 49**, las sociedades anónimas deben tener uno o más gerentes designados por el directorio, el cual fija las atribuciones y deberes del gerente, pudiendo sustituirlo a su arbitrio.

Al gerente o gerente general, en su caso, le corresponde la representación judicial de la sociedad, estando legalmente investido de las facultades establecidas en ambos incisos del **Art. 7° CPC**, y tiene derecho a voz en las reuniones de directorio, respondiendo con los miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales para la sociedad y los accionistas, cuando no consta su opinión contraria en el acta. Tiene derecho a voz, pero no a voto, lo cual es una facultad exclusiva de los directores.

El cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad, y en las sociedades anónimas abiertas, también con el de director.

Ya que el gerente cuenta con las facultades del **Art. 7° CPC**, se discute si es que tiene que ser abogado, pero se entiende por lo general que no es necesario.

La sociedad delega en el gerente general las facultades para representarla tanto en sede judicial como extrajudicial, pero ello no es óbice para que se dé cumplimiento a la **Ley N°18.120**. Si el gerente general no es abogado, se debe designar a uno para que asuma la representación judicial de la sociedad, pero el gerente general no necesitará la representación de un abogado para representar extrajudicialmente a la sociedad.

A los gerentes les son aplicables las disposiciones de la ley de Sociedades Anónimas que aplican para los directores en todo lo que sea compatible con las responsabilidades propias del cargo. Además, están sujetos a las mismas obligaciones, es decir, deber de reserva, confidencialidad, abstenerse de conflictos de interés, y los deberes genéricos de lealtad y preocupación respecto de la sociedad.

El gerente responde ante el directorio y no ante los accionistas, y es porque con estos últimos no tiene una relación contractual, al provenir sus atribuciones del directorio. Por lo mismo, si un accionista quisiera demandar al gerente general, tendría que hacer valer su responsabilidad extracontractual.

11) Director Independiente y Comité de Directores

El **Art. 50 bis** establece que las sociedades anónimas abiertas deben designar al menos un director independiente y un comité de directores cuando tengan un patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a 1.500.000 UF y a lo menos un 12,5% de sus acciones emitidas con derecho a voto se encuentren en poder de accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10% de tales acciones.

B) Inspectores de Cuentas y Auditores Externos

La fiscalización de la administración de la sociedad se lleva a cabo mediante los inspectores de cuentas o los auditores externos independientes, y la regulación varía según se trate de sociedades anónimas cerradas o abiertas.

1) En Sociedades Anónimas Cerradas

Conforme al **Art. 51**, las juntas ordinarias de las sociedades anónimas cerradas deben nombrar anualmente dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes, o bien auditores externos independientes, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y

otros estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima junta ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato.

Los inspectores de cuentas, además, pueden vigilar las operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones de los administradores y el fiel cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y estatutarios.

Sin embargo, los estatutos pueden eximir a la sociedad de estas obligaciones o establecer un mecanismo de control distinto.

Toda sociedad anónima, al ser comerciante, tiene la obligación de llevar contabilidad.

2) En Sociedades Anónimas Abiertas

Según dispone el **Art. 52**, la junta ordinaria de accionistas de las sociedades anónimas abiertas debe designar anualmente una empresa de auditoría externa con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad, y con la obligación de informar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.

Los estatutos pueden establecer, además, en forma permanente o transitoria, la existencia de inspectores de cuentas, con los mismos fines y facultades.

Si se presenta una querella contra un director por administración desleal, se discute si podría buscarse la responsabilidad penal del auditor externo. Para el profesor, como mucho, tendría responsabilidad como encubridor, ya que tiene la obligación de denunciar las faltas, aunque ello sigue siendo discutible. No obstante, siempre se podrá hacer valer la responsabilidad civil correspondiente por parte de los accionistas.

Cuando se habla de independientes, la ley apunta a que no tengan un interés directo o indirecto en el resultado de los negocios de la sociedad.

C) Juntas de Accionistas

1) Aspectos Generales

La Junta de Accionistas es la verdadera voluntad de la sociedad, al ser los accionistas quienes toman las decisiones fundamentales sobre la dirección de la sociedad. Esto se efectúa a través de la designación de los directores, que corresponde a las juntas de accionistas.

Pueden ser de dos tipos, conforme al **Art. 55**, según el cual los accionistas se reúnen en juntas ordinarias y extraordinarias.

Las juntas ordinarias se celebran al menos una vez en el año, en la fecha indicada en los estatutos, aunque por mandato de la ley, deben reunirse obligatoriamente dentro del primer cuatrimestre de cada año para aprobar el ejercicio del año anterior, por lo que normalmente se reúnen antes del 30 de abril de cada año.

Las juntas extraordinarias, por otra parte, pueden celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas, y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente.

2) Materias Propias de las Juntas de Accionistas

El **Art. 56** establece las **materias que son propias de las juntas ordinarias**, las cuales son:

- **Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores y liquidadores de la sociedad**

En una sociedad anónima cerrada muy pequeña se sabe rápidamente cuál es la situación financiera de la sociedad. Por ello, podría celebrarse la junta de accionistas el día 2 de enero. La ley estableció un plazo de cuatro meses porque cuando se promulgó, la contabilidad se llevaba a mano, y era mucho más difícil tener todo listo rápidamente y, además, aprobado por el Servicio de Impuestos Internos.

La obligación de celebrar la junta de accionistas es ineludible, y ello por la protección para terceros, ya que de otra forma no se puede saber la situación financiera de la sociedad.

- **La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos**

Conforme al **Art. 79**, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deben distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción establecida en los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

En las sociedades anónimas cerradas se está a lo determinado en los estatutos, y si estos nada dicen, se aplica la misma norma que para las sociedades anónimas abiertas. Prima por tanto la autonomía de la voluntad, pero no podemos olvidar que la repartición de utilidades es un elemento de la esencia del contrato de sociedad, por lo que no puede establecerse que nunca se repartan utilidades.

Podría establecerse que no se repartan utilidades por dos ejercicios para capitalizar las utilidades, ya que no es algo absoluto, sino una mera limitación.

- **La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración**
- **En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.**

Por otra parte, las **materias que son propias de las juntas extraordinarias** están señaladas en el **Art. 57**, y son:

- Disolución de la Sociedad;
- Transformación, Fusión o División de la Sociedad y Reforma de Estatutos;
- Emisión de Bonos o Debentures convertibles en Acciones;
- Enajenación del Activo de la Sociedad en los términos señalados en el **Art. 67 N°9**;
- Otorgamiento de Garantías Reales o Personales para caucionar Obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del directorio es suficiente;
- Las demás materias que por ley o por los estatutos correspondan a su conocimiento o a la competencia de las juntas de accionistas.

En los cuatro primeros casos, la junta debe celebrarse ante notario, quien debe certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.

Respecto del cuarto caso, debemos destacar que con enajenación, la ley se refiere tanto a la transferencia del dominio como a la constitución de derechos reales. Además, los términos del **Art. 67 N°9** se refieren a la enajenación de 50% o más del activo de la sociedad y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje, o la enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la sociedad, como cualquier enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador.

Respecto del quinto caso, con caución nos referimos a cualquier obligación contraída para garantizar una obligación propia o ajena, como la fianza, la prenda y la hipoteca. Además, si se cauciona más del 50% del activo, estaremos dentro del cuarto caso.

Por otro lado, es necesario determinar lo que entendemos por terceros, y a tal respecto varios fallos han determinado que cuando se trata de operaciones realizadas entre empresas relacionadas, según lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, no se trata de terceros, y por lo tanto, no se requiere junta extraordinaria de accionistas. Sin embargo, hay otros fallos, que se han dado sobre todo en la Corte de Apelaciones de Concepción, y según las cuales, la ley no distingue materia societaria para juntas de accionistas si se trata de terceros absolutos o relativos, por lo que es nula la caución otorgada sin una junta extraordinaria de accionistas celebrada al efecto.

3) Convocatorias a las Juntas de Accionistas

Conforme al **Art. 58**, las juntas, sean ordinarias o extraordinarias, deben ser convocadas por el directorio de la sociedad, el cual debe convocar a:

- Junta ordinaria, a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance, con el fin de conocer de todos los asuntos de su competencia;
- Junta extraordinaria, siempre que, a su juicio, los intereses de la sociedad lo justifique;
- Junta ordinaria o extraordinaria, según el caso, cuando así lo soliciten accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta;
- Junta ordinaria o extraordinaria, según el caso, cuando así lo requiera la Comisión para el Mercado Financiero, con respecto a las sociedades anónimas abiertas o especiales, sin perjuicio de su facultad para convocarlas directamente.

En el caso de las sociedades anónimas cerradas, si el directorio no ha convocado a junta cuando corresponde, los accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, pueden efectuar la citación a junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, mediante la publicación de un aviso en un diario de circulación nacional, en el cual deben expresar la fecha y hora en que se llevará a cabo y los asuntos a tratar en la junta.

Las juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas o de la Comisión para el Mercado Financiero, deben celebrarse dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha de la respectiva solicitud.

Se discute si puede convocarse a una junta de accionistas en un día inhábil. El profesor lo considera válido, ya que la ley no distingue entre días hábiles e inhábiles para su convocación.

Conforme al **Art. 59**, la citación a la junta de accionistas se efectúa por medio de un aviso destacado que se publica, al menos, por tres veces en días distintos en el periódico del domicilio social que haya determinado la junta de accionistas o, a falta de acuerdo o en caso de suspensión o desaparición de la circulación del periódico designado, en el Diario Oficial.

En sociedades anónimas abiertas, además, debe enviarse una citación por correo a cada accionista con una anticipación mínima de quince días a la fecha de la celebración de la junta, la cual debe contener una referencia a las materias a ser tratadas en ella e indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, los que deben, además, ponerse a disposición de los accionistas en el sitio web de las sociedades que dispongan de tales medios.

La omisión de esta obligación no afecta la validez de la citación, pero los directores, liquidadores y gerente de la sociedad infractora responden de los perjuicios que causen a los accionistas, no obstante las sanciones administrativas que pueda aplicar la Comisión para el Mercado Financiero.

Sin perjuicio de lo anterior, el **Art. 60** dispone que pueden auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.

En virtud del **Art. 61**, las juntas se constituyen en primera citación, salvo que la ley o los estatutos establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su número, y los acuerdos se adoptan por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto.

Los avisos de la segunda citación sólo pueden publicarse una vez que fracasa la junta a efectuarse en primera citación, y en todo caso, la nueva junta debe ser citada para celebrarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada para la junta no efectuada.

Las juntas son presididas por el presidente del directorio o por el que haga sus veces, y actúa como secretario el titular de este cargo, cuando lo hubiere, o el gerente en su defecto.

Las Sociedades Anónimas Abiertas y Especiales deben comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero la celebración de toda junta de accionistas, con una anticipación no inferior a quince días (**Art. 63**).

En las juntas de accionistas, los titulares pueden actuar por sí o representados, pudiendo otorgar un poder o un mandato a un tercero para que represente al titular en las juntas de accionistas.

Para efectos de los acuerdos, los accionistas pueden acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuir sus votos en la manera que estimen convenientes.

4) Quóruns para la Adopción de Acuerdos

Los acuerdos de la junta extraordinaria que impliquen reforma de los estatutos sociales o el saneamiento de la nulidad de modificaciones de ellos causada por vicios formales, deben ser adoptados con la mayoría que determinen los estatutos, la cual, en las sociedades anónimas cerradas, no puede ser inferior a la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto (**Art. 67**).

Por otra parte, requieren del voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto los acuerdos relativos a:

- La transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad;
- La modificación del plazo de duración de la sociedad cuando lo hubiere;
- La disolución anticipada de la sociedad;
- El cambio de domicilio social;
- La disminución del capital social;
- La aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero;
- La modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio;
- La disminución del número de miembros del directorio;
- La enajenación del 50% o más del activo y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje o la enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la sociedad, como cualquier enajenación que implique que la matriz pierda el carácter de controlador;
- La forma de distribuir los beneficios sociales;
- El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros que excedan el 50% del activo, excepto respecto de filiales, caso en el cual la aprobación del directorio es suficiente;
- La adquisición de acciones de su propia emisión;
- Las demás que señalen los estatutos;
- El saneamiento de la nulidad causada por vicios formales de que adolezca la constitución o una modificación;
- En las sociedades anónimas abiertas, establecer el derecho de compra;
- Aprobar o ratificar la celebración de actos o contratos con partes relacionadas.

5) Derecho a Retiro

Los **Arts. 69-71 bis** tratan el derecho a retiro, que es el derecho que tiene un accionista para retirarse de la sociedad cuando se opone a ciertos acuerdos, estando facultado para que la sociedad le pague el valor de sus acciones.

Los acuerdos que dan origen al derecho a retiro de la sociedad son:

- La transformación de la sociedad;
- La fusión de la sociedad;
- La enajenación contemplada en el **Art. 67 N°9**;
- El otorgamiento de las cauciones a que se refiere el **Art. 67 N°11**;
- La creación de preferencia para una serie de acciones o el aumento, prórroga o la reducción de las ya existentes. En este caso, sólo tienen derecho a retiro los accionistas disidentes de la o las series afectadas;
- El saneamiento de la nulidad causada por vicios formales de que adolezca la constitución de la sociedad o alguna modificación de sus estatutos que diere este derecho;
- Los demás casos que establezcan la ley o los estatutos.

La aprobación por la junta de accionistas de alguna de estas materias concede al accionista disidente el derecho a retirarse de la sociedad, previo pago por aquella del valor de sus acciones.

Sin perjuicio de esto último, en el caso en que la sociedad tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, se suspende el ejercicio del derecho a retiro hasta que no sean pagadas las acreencias que existan al momento de generarse ese derecho.

Se considera accionista disidente a aquel que en la respectiva junta se opone al acuerdo que da derecho a retiro o que, no habiendo concurrido a la junta, manifieste su disidencia por escrito a la sociedad dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de celebración de la junta de accionistas que adoptó el acuerdo que lo motiva.

El precio a pagar por la sociedad al accionista disidente que ejerce su derecho de retiro es el valor de libros de la acción en sociedades anónimas cerradas, y el valor de mercado de la acción en sociedades anónimas abiertas.

Por otro lado, el accionista disidente puede además querellarse por administración desleal, conforme a la **Ley N°21.121**.

Cuando se celebran juntas de accionistas y el accionista no se opone a la celebración de un acuerdo, no puede luego ejercer el derecho de retiro, pues al no haberse opuesto, no se considera accionista disidente.

En cuanto a la naturaleza del pago del valor de las acciones, podríamos incluso entenderlo como una especie de indemnización de perjuicios, ya que el accionista disidente ejerce este derecho porque el acuerdo adoptado puede generarle algo parecido a un lucro cesante.

Además, puede ejercerse como una presión para la junta de accionistas, de manera que reevalúen la adopción del acuerdo, y si se ratifica, quedará firme el derecho a retiro.

El directorio puede convocar a una nueva junta que debe celebrarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo que tiene el accionista disidente para ejercer su derecho a retiro, con el fin de que reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron el ejercicio del derecho a retiro. Si en la junta se revocan los acuerdos, caduca el derecho a retiro.

El precio de las acciones se paga sin recargo dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la celebración de la junta en que se tomó el acuerdo que motivó el retiro. Si no se paga dentro de dicho término, el precio debe expresarse en UF y devenga intereses corrientes a contar del vencimiento del plazo.

El **Art. 71 bis** contempla otro caso de derecho a retiro, a favor de los accionistas minoritarios cuando un controlador adquiera más del 95% de las acciones de una sociedad anónima abierta.

Este derecho debe ejercerse dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha en que el accionista controlador alcance la participación indicada, lo cual se comunica dentro de los dos días hábiles siguientes a través de un aviso destacado publicado en un diario de circulación nacional y en el sitio web de la sociedad, si ella dispone de tales medios.

El ejercicio del derecho a retiro no implica la renuncia a las acciones legales respectivas a cualquier otro daño generado al accionista, como si se descubriera que las acciones valían más de lo que se pagó. Incluso, si se estableciera en los estatutos que el ejercicio del derecho a retiro implica la renuncia de estas acciones, tal cláusula sería nula.

Respecto de las deliberaciones y acuerdos de las juntas, se debe dejar constancia en un libro de actas, el cual es llevado por el secretario, si lo hubiera, o en su defecto, por el gerente.

Las actas son firmadas por quienes actuaron de presidente y secretario de la junta, y por tres accionistas elegidos en ella, o por todos los asistentes si fueran menos de tres.

El acta se entiende aprobada desde el momento de su firma por estas personas, y desde su fecha pueden llevarse a cabo los acuerdos a que se refiere.

5. Pago de los Dividendos

Según dispone el **Art. 78**, los dividendos se pagan exclusivamente de las utilidades líquidas del ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados por juntas de accionistas.

La utilidad líquida es aquella que se obtiene del ejercicio descontando todos los costos, gastos e impuestos.

Si la sociedad tiene pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinan primeramente a absorberlas. Si hay pérdidas en un ejercicio, éstas son absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas.

Salvo que la junta respectiva acuerde algo distinto por unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deben distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiese acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En las sociedades anónimas cerradas, se está a lo dispuesto en los estatutos, y si estos nada dicen, aplica la misma norma que para las abiertas.

Todo lo que no se reparte como dividendo puede capitalizarse, conforme al **Art. 80**.

El pago de los dividendos mínimos obligatorios que corresponda de acuerdo a la ley o a los estatutos se hace exigible transcurridos treinta días contados desde la fecha de la junta que aprueba la distribución de las utilidades del ejercicio.

El pago de los dividendos adicionales que acordare la junta se hace dentro del ejercicio en que se adopte el acuerdo y en la fecha que ésta determine o en la que fije el directorio, si la junta lo hubiere facultado para ello.

Luego, salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas, los dividendos deben pagarse en dinero, aunque en las sociedades anónimas abiertas se puede cumplir con la obligación de pagar dividendos, en lo que excede los mínimos obligatorios, otorgando opción a los accionistas para recibirlos en dinero, acciones liberadas de la propia emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas de que la empresa sea titular.

Por último, los dividendos y demás beneficios en efectivo no reclamados por los accionistas dentro del plazo de cinco años desde que se hayan hecho exigible, pertenecen a los Cuerpos de Bomberos de Chile, conforme al **Art. 85**.

6. Sociedades Filiales y Coligadas

Antes de entrar en concreto a la regulación de las sociedades filiales y coligadas, debemos primero destacar algunos conceptos que contempla la **Ley de Mercado de Valores**.

Primero, debemos saber lo que se entiende por **Grupo Empresarial**, concepto contenido en el **Art. 96 Inc. 1°** de la **Ley de Mercado de Valores**: “*Grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten*”.

La misma disposición establece que forman parte de un mismo grupo empresarial:

- Una sociedad y su controlador;
- Sociedades que tienen un controlador común, y este último;
- Entidades que determine la Comisión para el Mercado Financiero.

Luego, el **Art. 97** de la **Ley de Mercado de Valores** define lo que debe entenderse por **Controlador**, al disponer: *“Es controlador de una sociedad toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras persona naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones:*

a) Asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos, en otro tipo de sociedades, o

b) Influir decisivamente en la administración de la sociedad.

Cuando un grupo de personas tiene acuerdo de actuación conjunta para ejercer alguno de los poderes señalados en las letras anteriores, cada una de ellas se denominará miembro del controlador.

En las sociedades en comandita por acciones se entenderá que es controlador el socio gestor”.

Por último, el **Art. 100** de la **Ley de Mercado de Valores** establece el concepto de **Personas Relacionadas**, al disponer: *“Son relacionadas con una sociedad las siguientes personas:*

a) Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad;

b) Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N°18.046;

c) Quienes sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos, y

d) Toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones”.

Estos conceptos son de gran importancia para entender la materia que estudiaremos a continuación, y además, por lo que son el abuso del derecho y la doctrina del levantamiento del velo, temas contenidos en textos complementarios a la clase.

Conforme al **Art. 86** de la **Ley de Sociedades Anónimas**, es **sociedad filial** de una sociedad anónima, que se denomina **matriz**, aquella en la que ésta controla directamente o través de otra persona natural o jurídica, más del 50% de su capital con derecho a voto, o del capital si no se tratare de una sociedad por acciones, o pueda elegir, designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores.

Una sociedad en comandita es también filial de una sociedad anónima cuando ésta tenga el poder para dirigir u orientar la administración del gestor.

Por otro lado, el **Art. 87** dispone que es **sociedad coligada** con una sociedad anónima aquella en la que ésta, que se denomina **coligante**, sin controlarla, posee directamente o a través de otra persona natural o jurídica el 10% o más de su capital con derecho a voto, o del capital si no se tratare de una sociedad por acciones, o pueda elegir, designar o hacer elegir o designar por lo menos un miembro del directorio o de la administración de la misma.

La sociedad en comandita es también coligada de una anónima cuando ésta pueda participar en la designación del gestor o en la orientación de la gestión de la empresa que éste ejerza.

Tanto las sociedades filiales como coligadas de una sociedad anónima tienen la prohibición de tener participación recíproca en sus respectivos capitales, o en el capital de la matriz o de la coligante, incluso en forma indirecta a través de otras personas naturales o jurídicas.

La participación recíproca que ocurre en virtud de incorporación, fusión, división o adquisición del control por una sociedad anónima deben constar en las respectivas memorias y terminar en el plazo de un año desde que el evento ocurra.

La prohibición también rige cuando la matriz o coligante, en su caso, no fuera una sociedad anónima, siempre que sí lo sea una de sus filiales o coligadas.

En el caso de las sociedades anónimas cerradas, las operaciones entre sociedades coligadas, entre la matriz y sus filiales, las de estas últimas entre sí o con las coligadas, y aquellas realizadas con sus personas relacionadas, deben observar condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

Los directores de una sociedad matriz, aunque no sean miembros del directorio de una sociedad filial o administradores de la misma, pueden asistir con derecho a voz a las reuniones de dichos directorios o a las de los administradores, en su caso, y tienen además, facultad para imponerse de los libros y antecedentes de la sociedad filial (**Art. 92**).

Por otro lado, y conforme al **Art. 90 inc. 1º**, en la memoria anual, el directorio debe señalar las inversiones de la sociedad en sociedades coligadas o filiales y las modificaciones ocurridas en ellas durante el ejercicio, debiendo dar a conocer a los accionistas los balances de dichas empresas y una memoria explicativa de sus negocios.

7. División, Transformación y Fusión de la Sociedad Anónima

La **división** de la Sociedad Anónima no es un tema muy tratado en la ley, aunque sí tiene mucha contingencia tributaria.

Conforme al **Art. 94 LSA**, la división de una sociedad anónima consiste en la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyan al efecto, correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades que aquella que poseían en la sociedad que se divide.

Así, hablamos de la distribución de un patrimonio. Por ejemplo, una empresa de hamburguesas se divide para la creación de otra que vende empanadas, distribuyendo el capital social en dos partes iguales. Si había cuatro accionistas en la primera, seguirán siendo los mismos, y su participación accionaria en la nueva sociedad será la misma que tenían en la sociedad anterior.

Como mencionamos anteriormente, la división de una sociedad anónima es materia de una junta extraordinaria de accionistas, y a tal respecto, el **Art. 95 LSA** dispone: “*La división debe acordarse en junta general extraordinaria de accionistas en la que deberán aprobarse las siguientes materias:*

- 1) La disminución del capital social y la distribución del patrimonio de la sociedad entre ésta y la nueva o nuevas sociedades que se crean;*
- 2) La aprobación de los estatutos de la o de las nuevas sociedades a constituirse, los que podrán ser diferentes a los de la sociedad que se divide, en todas aquellas materias que se indiquen en la convocatoria. Esta aprobación incorpora de pleno derecho a todos los accionistas de la sociedad dividida en la o las nuevas sociedades que se formen”.*

Si la sociedad original hubiese tenido un inmueble y ese inmueble se aporta a la nueva sociedad, el SII ha determinado en varios oficios que no es necesario inscribir nuevamente la propiedad, ya que la participación accionaria se mantiene igual, aunque conforme al sistema registral, debe inscribirse la nueva propiedad en el Registro del Conservador de Bienes Raíces respectivo, ya que las sociedades son personas jurídicas distintas de los accionistas individualmente considerados, y por lo mismo, sí cambia de manos la propiedad.

Los estatutos de la nueva sociedad deben aprobarse, y todos los trámites para la constitución de la sociedad deben llevarse a cabo, siendo lo único distinto a lo normal que el capital proviene de la sociedad anterior y que los accionistas mantienen su porcentaje en la participación.

Según dispone el **Art. 96 LSA**, la **transformación** es el cambio de especie o tipo social de una sociedad, efectuado por reforma de estatutos y subsistiendo la personalidad jurídica.

Muchas veces se ha intentado oponer a una demanda en contra de una sociedad transformada excepciones por falta de emplazamiento, pero ya que la personalidad jurídica subsiste, la demanda se entiende emplazada.

En cualquier caso, la transformación de la sociedad implica que la sociedad resultante debe cumplir con todos los requisitos y solemnidades de inscripción que establece la ley para el tipo de sociedad en el cual se transforma.

Art. 97: “*En la transformación de otros tipos o especies de sociedades en sociedades anónimas, sólo deberá cumplirse con las formalidades señaladas en el artículo 5° de esta ley y si se tratare de transformación en sociedades anónimas especiales, con las que específicamente se hubiere consignado para éstas.*

Si la transformación fuere de sociedad anónima a otro tipo o especie de sociedad, deberá cumplirse con las formalidades propias de ambos tipos sociales”.

Art. 98: “*La transformación de sociedades en comandita o colectivas en sociedades anónimas, no libera a los socios gestores o colectivos de la sociedad transformada de su responsabilidad por las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la sociedad, salvo respecto de los acreedores que hayan consentido expresamente en ella”.*

Lo habitual es que una sociedad de personas se transforme en una de capital, y no al revés.

Conforme al **Art. 99 LSA**, la **fusión** consiste en la reunión de dos o más sociedades en una sola que las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y accionistas de los entes fusionados.

Conforme al mismo artículo, podemos distinguir entre dos tipos de fusión:

- **Fusión por Creación:** Cuando el activo y el pasivo de dos o más sociedades que se disuelven se aportan a una nueva sociedad que se constituye;
- **Fusión por Incorporación:** Cuando una o más sociedades que se disuelven son absorbidas por una sociedad ya existente, la cual adquiere todos sus activos y pasivos.

En estos casos, no procede la liquidación de las sociedades fusionadas o absorbidas, ya que la sociedad absorbente o la nueva sociedad suceden a la absorbida o anteriores en todos sus derechos y obligaciones.

La doctrina habla de un tercer tipo de fusión, llamada **Fusión Impropia**. Se trata de casos en que una persona adquiere el 100% del capital accionario, aunque la Corte Suprema ha señalado que en estos casos no existe fusión, ya que no se cumplen los elementos del **Art. 99 LSA**.

El principio más relevante tanto en materia de fusiones como de transformaciones y divisiones está en el **Art. 100**, conforme al cual, ningún accionista, salvo que consienta en ello, puede perder su calidad de tal con motivo de un canje de acciones, fusión, incorporación, transformación o división de una sociedad anónima.

8. Disolución y Liquidación de la Sociedad Anónima

Según dispone el **Art. 103 LSA**, la Sociedad Anónima se **disuelve** por:

- El vencimiento del plazo para su duración, si lo hubiere;
- Por reunirse todas las acciones en una sola persona por un período ininterrumpido que exceda de diez días;
- Por acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas;
- Por revocación de la autorización de existencia conforme a la ley;
- Por sentencia judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades anónimas cerradas;
- Por las demás causales contempladas en el estatuto.

Respecto del quinto caso, es difícil que una sentencia ejecutoriada ponga término a una sociedad, y por lo general lo que se declara es la nulidad o inexistencia de la sociedad por vicios en su constitución, ya que ponerle fin a la vida de una persona por sentencia judicial sería algo absurdo.

Respecto de esta materia, el **Art. 105** dispone: *“Las sociedades anónimas a que se refiere el N°5 del artículo 103 de la presente ley, podrán ser disueltas por sentencia judicial ejecutoriada, cuando accionistas que representen a lo menos un 20% de su capital así lo demandaren, por estimar que existe causa para ello, tales como infracción grave de ley, de reglamento o demás normas que les sean aplicables, que causare perjuicio a los accionistas o a la sociedad; dictación de la resolución de liquidación de la sociedad, administración fraudulenta u otras de igual gravedad.*

El tribunal procederá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia”.

El problema se da porque la forma en que conoce el tribunal hace difícil la indemnización de perjuicios, y al ser una norma perjudicial para los accionistas, se hace inaplicable en la práctica.

Conforme al **Art. 108**, la disolución que se produce por las causas de vencimiento del plazo, reunión de todas las acciones en una sola persona o cualquier causa contemplada en el estatuto, el directorio debe consignar estos hechos por escritura pública dentro del

plazo de treinta días de producidos, y un extracto de ella debe ser inscrito y publicado en la forma prevista en el **Art. 5°**.

Cuando la disolución se origina por resolución de revocación de la Superintendencia o por sentencia judicial ejecutoriada, en su caso, el directorio debe hacer tomar nota de esta circunstancia al margen de la inscripción de la sociedad y publicar, por una sola vez, un aviso en el Diario Oficial, informando de esta ocurrencia.

Transcurridos sesenta días de acaecidos los hechos antes indicados sin que se hubiera dado cumplimiento a las formalidades establecidas, cualquier director, accionista o tercero interesado puede dar cumplimiento a ellas.

La falta de cumplimiento de estas exigencias hace solidariamente responsables a los directores de la sociedad por el daño y perjuicios causados con motivo de ese incumplimiento.

Disuelta la sociedad, se procede a su **liquidación**, y el principio básico para esto está en el **Art. 109 LSA**, conforme al cual, la sociedad anónima disuelta subsiste como persona jurídica para los efectos de su liquidación, quedando vigentes sus estatutos en lo que fuere pertinente.

En estos casos, a la razón social deben agregarse las palabras “en liquidación”.

Durante la liquidación, la sociedad sólo puede ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan directamente a facilitarla, no pudiendo en caso alguno continuar con la explotación del giro social.

Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que la sociedad puede efectuar operaciones ocasionales o transitorias de giro, a fin de lograr la mejor realización de los bienes sociales.

Luego, según dispone el **Art. 110 LSA**, disuelta la sociedad, se procede a su liquidación por una comisión liquidadora elegida por la junta de accionistas en la forma dispuesta por el **Art. 66**, la cual fija su remuneración.

De igual manera se procede para la liquidación de las sociedades declaradas nulas.

Si la sociedad se disuelve por reunirse las acciones en manos de una sola persona, no es necesaria la liquidación.

Si la disolución de la sociedad hubiere sido decretada por sentencia ejecutoriada, la liquidación se practica por un solo liquidador elegido por la Junta General de Accionistas de una quina que le presentará el tribunal, en aquellos casos en que la ley no encomiende dicha función a la Superintendencia o a otra autoridad.

Por otra parte, el **Art. 115** dispone que, durante la liquidación, continúan reuniéndose las juntas ordinarias, y en ellas se da cuenta por los liquidadores del estado de la liquidación, y se acuerdan las providencias necesarias para llevarla a cumplido término.

Los liquidadores deben enviar, publicar y presentar los balances y demás estados financieros que establece la Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias.

Los liquidadores deben convocar extraordinariamente a junta general, conforme al **Art. 58** de la ley.

Las funciones de la comisión liquidadora o del liquidador en su caso, no son delegables. Con todo, pueden delegar parte de sus facultades en uno o más liquidadores si fueren varios, y para objetos especialmente determinados, en otras personas.

Cuando la liquidación la practique el Superintendente por sí o por delegados, debe convocar a junta de accionistas sólo cuando lo estime necesario o se lo soliciten para fines de información, accionistas que posean a lo menos el 10% de las acciones emitidas.

Concluida la liquidación, debe comunicar esta circunstancia por tres avisos consecutivos en un periódico del domicilio social y proporcionar una información general del proceso de liquidación a aquellos accionistas que lo soliciten dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del último aviso.

Durante la liquidación se mantiene la obligación de celebrar las juntas de accionistas, siendo recomendable la disolución de ellas para evitar que la sociedad se mantenga activa durante su liquidación.

9. Arbitraje

Sabemos de antemano que todos los conflictos entre accionistas son materia de **arbitraje forzoso**. A tal respecto, el **Art. 125** dispone: *“En los estatutos sociales se establecerá la forma como se designarán el o los árbitros que conocerán las materias a que se refiere el N°10 del artículo 4° de la presente ley. En caso alguno podrá nominarse en ellos a una o más personas determinadas como árbitros.*

El arbitraje que establece esta ley es sin perjuicio de que, al producirse un conflicto, el demandante pueda sustraer su conocimiento de la competencia de los árbitros y someterlo a la decisión de la justicia ordinaria. Este derecho no podrá ser ejercido por los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la sociedad.

Tampoco por aquellos accionistas que individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 unidades de fomento, de acuerdo al valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda”.

Así, aunque los problemas entre accionistas sean materia de arbitraje forzoso, los accionistas tienen derecho, al producirse el conflicto, de sustraer su conocimiento de la competencia de los árbitros, sometiéndolo a la decisión de la justicia ordinaria.

Ahora bien, se entiende que si en los estatutos se estableció la naturaleza del arbitraje y la forma de designación de los árbitros, no puede luego recurrir a la justicia ordinaria. Esta norma, por tanto, sólo es aplicable cuando los estatutos no digan nada respecto del arbitraje.

10. Responsabilidades y Sanciones

Art. 133 LSA: *“La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es sin perjuicio de las demás sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan.*

Por las personas jurídicas responderán además civil, administrativa y penalmente, sus administradores o representantes legales, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción.

Los directores, gerentes y liquidadores que resulten responsables en conformidad a los incisos anteriores, lo serán solidariamente entre sí y con la sociedad que administren, de todas las indemnizaciones y demás sanciones civiles o pecuniarias derivadas de la aplicación de las normas a que se refiere esta disposición”.

No existe distinción respecto de la persona que cometa la infracción para la configuración de responsabilidad, pero es necesario que se ocasione un daño, el cual debe probarse.

Luego, según dispone el **Art. 133 bis**, toda pérdida irrogada al patrimonio de la sociedad como consecuencia de una infracción a esta ley, su reglamento, los estatutos sociales, las normas dictadas por el directorio en conformidad a la ley o las normas que imparta la Superintendencia, dará derecho a un accionista o grupo de accionistas que representen, a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquiera de los directores

de la sociedad, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio de la sociedad.

Las costas a que hubiere lugar son pagadas a los demandantes y no pueden beneficiar a la sociedad de forma alguna. Por su parte, si los accionistas o el director son condenados en costas, son exclusivamente responsables de ellas.

Estas normas son de gran importancia, ya que establecen el estatuto de responsabilidad, pero se requiere un juicio de lato conocimiento que queda subordinado a la **Ley N°21.121**.

Unidad V – Sociedad por Acciones

1. Aspectos Generales

Al igual que la Sociedad Anónima, la Sociedad por Acciones es una sociedad de capital, teniendo ciertas particularidades, al existir mayor autonomía en cuanto a la regulación de la administración, por ejemplo.

Fue establecida por la **Ley N°20.190** de 2007, que modificó varios cuerpos legales, incluido el Código de Comercio, en el cual quedó contemplada en los **Arts. 424 y ss.**

Art. 424 CdC: *“La sociedad por acciones, o simplemente la “sociedad” para los efectos de este Párrafo, es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones.*

La sociedad tendrá un estatuto social en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de su administración y los demás pactos que, salvo por lo dispuesto en este Párrafo, podrán ser establecidos libremente. En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este Párrafo, la sociedad se regirá supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas”.

Hablamos de una persona jurídica, teniendo también por tanto los mismos atributos de la personalidad que las demás sociedades que hemos estudiado.

Podemos ver la primera gran diferencia con las demás sociedades en este artículo, ya que dispone que puede ser creada por una sola persona, por lo que es posible que una sola persona concurre a su acto constitutivo, aunque no es el fin perseguido por el legislador que la sociedad por acciones esté en manos de una sola persona, y es por ello que se habla de la creación de la persona jurídica.

En cualquier caso, el **Art. 444** dispone que, salvo que el estatuto disponga lo contrario, la sociedad no se disuelve por reunirse todas las acciones en un mismo accionista.

Además, se habla de acto de constitución, y no necesariamente de escritura pública, y siendo la participación en el capital representada por acciones, al igual que en la sociedad anónima.

Al igual que en las demás sociedades, se debe contar con un estatuto social en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de administración y demás pactos entre accionistas.

Además, rigen supletoriamente las normas que rigen a las sociedades anónimas cerradas en todo lo que no se oponga a la naturaleza de las sociedades por acciones.

Es importante tener en cuenta el **Art. 430 CdC**, conforme al cual, la sociedad por acciones que durante más de 90 días seguidos tiene 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas excedan dicho porcentaje, por el sólo ministerio de la ley se transforman en sociedades anónimas, siéndoles plenamente aplicables las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, que prevalecen sobre el estatuto social.

En tales casos, la siguiente junta de accionistas debe resolver las adecuaciones que reflejen la nueva modalidad social y elegir los miembros del directorio que continuará la administración.

Prima por sobre todo la autonomía de la voluntad al establecer la administración social, pero siempre respetando la buena fe, derechos de terceros y demás principios generales

en materia societaria, aplicándose por analogía las normas respecto de los deberes y responsabilidad de los directores.

2. Constitución de la Sociedad por Acciones

Conforme al **Art. 425**, la sociedad por acciones se forma, existe y prueba por un acto de constitución social escrito, inscrito y publicado en los términos del **Art. 6°**, que se perfecciona mediante escritura pública o por instrumento privado suscrito por sus otorgantes, y cuyas firmas sean autorizadas por notario público, en cuyo registro se protocoliza el instrumento.

El cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación del acto de constitución de la sociedad produce efectos desde la fecha de la escritura o de la protocolización del instrumento privado, según corresponda.

Hay que tener siempre en cuenta que el instrumento privado no produce plena prueba en juicio, por lo que en ese sentido puede ser más conveniente la escritura pública, y para que se otorgue boleta por la constitución y esta quede como gasto social, es necesario que se haga por escritura pública.

En general, por ello, es más conveniente hacer la constitución por escritura pública, sin perjuicio de que es pecuniariamente más costoso que el instrumento privado.

La ley permite que se haga por instrumento privado para facilitar los emprendimientos.

El **Inc. 2° del Art. 425** establece las menciones mínimas de los estatutos, las cuales son:

- El nombre de la sociedad, que debe concluir con la expresión “SpA”;
- El objeto de la sociedad, que se considera siempre mercantil;
- El capital de la sociedad y el número de acciones en que el capital es dividido y representado;
- La forma en que se ejercerá la administración de la sociedad y se designarán sus representantes, con indicación de quienes la ejercerán provisoriamente, en su caso;
- La duración de la sociedad, que puede ser indefinida, y si nada se dice, se entiende indefinida.

Respecto de la **inscripción y publicación**, el **Art. 426** dispone que, dentro del plazo de un mes contado desde la fecha del acto de constitución social, un extracto del mismo, autorizado por el notario respectivo, debe inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial.

A su vez, el extracto debe contener ciertas menciones mínimas, las cuales son:

- El nombre de la sociedad;
- El nombre de los accionistas concurrentes al instrumento de constitución;
- El objeto social;
- El monto a que asciende el capital suscrito y pagado de la sociedad;
- La fecha de otorgamiento, el nombre y domicilio del notario que autorizó la escritura o que protocolizó el instrumento privado de constitución que se extracta, así como el registro y número de rol o folio en que se ha protocolizado dicho documento.

Los efectos de la publicación y la inscripción se retrotraen a la fecha de otorgamiento del acto de constitución, por lo que puede actuarse antes de la inscripción y publicación, aunque en la práctica, es difícil que terceros quieran contratar con una sociedad que aún no se encuentra inscrita.

Luego, el **Art. 427** trata el tema de las modificaciones al estatuto social, al establecer que las disposiciones del estatuto social son modificadas por acuerdo de la junta de accionistas, del que se deja constancia en un acta protocolizada o reducida a escritura pública.

Sin embargo, no se requiere la celebración de esta junta de accionistas si la totalidad de los accionistas suscriben una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste la modificación.

Un extracto del documento de modificación o del acta respectiva, según el caso, debe inscribirse y publicarse en la misma forma que en la constitución.

Lógicamente, cuando sólo hay un accionista, puede modificar los estatutos individualmente.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el **Art. 428** dispone que en caso de omisión de algún requisito o mención en los estatutos o el extracto, son aplicables las normas de saneamiento de nulidad que contempla la Ley de Sociedades Anónimas.

El saneamiento de las nulidades que afectan la constitución y modificaciones de sociedades por acciones se efectúa conforme a la Ley de Saneamiento.

Si no es procedente el saneamiento, los accionistas pueden liquidar por sí mismos la sociedad de hecho o designar a uno o más liquidadores, aunque debemos tener en cuenta que, al igual que en la sociedad anónima, la personalidad jurídica se mantiene hasta la liquidación.

3. Normas Generales

A) Responsabilidad de los Accionistas

Conforme al **Art. 429 CdC**, los accionistas sólo son responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, por lo que entendemos que es una sociedad de responsabilidad limitada, al igual que la sociedad anónima.

Lógicamente, el aporte no puede embargarse, al dejar de pertenecer a los accionistas y pasar a la sociedad, que es una persona jurídica distinta.

Las acciones pueden rematarse, sin embargo, conforme a las normas del CPC, y sin que sea necesario un precio mínimo, al ser un bien mueble. Lo normal en las sociedades de capital es que no se proceda al remate, sino al pago por subrogación.

B) Registro de Accionistas

Según dispone el **Art. 431**, la sociedad por acciones debe llevar un registro en el que se anota, al menos, el nombre, domicilio y cédula de identidad o rol único tributario de cada accionista, el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y, tratándose de acciones inscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de pago de ellas.

En el registro también debe inscribirse la constitución de gravámenes y derechos reales distintos al dominio, y en caso que un accionista transfiera el todo o parte de sus acciones, debe anotarse esta circunstancia en el registro.

El registro puede llevarse por cualquier medio, siempre que ofrezca seguridad de que no puede haber intercalaciones, supresiones u otra adulteración que pueda afectar su fidelidad y que, además, permita el inmediato registro o constancia de las anotaciones que deban hacerse, y debe estar disponible en todo tiempo para su examen por cualquier accionista o administrador de la sociedad.

Los administradores y el gerente general de la sociedad son solidariamente responsables de los perjuicios causados a los accionistas y terceros con ocasión de la falta de fidelidad o vigencia de las informaciones contenidas en el registro de accionistas.

C) Nombre, Domicilio y Objeto Social

Como ya dijimos anteriormente, el **nombre** de la sociedad debe terminar con la expresión “SpA”.

Según dispone el **Art. 432 CdC**, si el nombre de una sociedad fuere idéntico o semejante a otra ya existente, ésta tiene derecho a demandar la modificación del nombre de aquella mediante juicio sumario.

El **domicilio social** no es una de las menciones mínimas de los estatutos, aunque conforme al **Art. 433**, la sociedad debe tener un domicilio. Si la mención se omite en la escritura social, la sociedad se entiende domiciliada en el lugar de otorgamiento de ésta.

La sociedad puede tener por **objeto** cualquiera que no sea contrario a la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres.

El objeto puede ser singular o múltiple, al igual que en la sociedad anónima, y se considera siempre mercantil.

4. Capital Social

Conforme al **Art. 434**, el capital de la sociedad debe ser fijado de manera precisa en los estatutos, y se divide en un número determinado de acciones nominativas. Se puede establecer que las acciones de la sociedad sean emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos.

Los **aumentos de capital** son acordados por los accionistas, sin perjuicio de que el estatuto puede facultar a la administración en forma general o limitada, temporal o permanentemente, para aumentar el capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la sociedad o para fines específicos.

El capital social y sus posteriores aumentos deben quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo indicado en los estatutos, que es de cinco años contados desde la constitución de la sociedad o el aumento respectivo si nada se dice.

Si no se paga oportunamente al vencimiento del plazo, el capital se reduce al monto efectivamente suscrito y pagado, y salvo disposición en contrario en los estatutos, las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado no gozan de derecho alguno, a diferencia de lo que ocurre en las Sociedades Anónimas.

El estatuto social puede establecer porcentajes o montos mínimos o máximos del capital que puede ser controlado por uno o más accionistas de forma directa o indirecta. En caso de existir estas normas, el estatuto debe contener disposiciones que regulen los efectos y establezcan las obligaciones o limitaciones que nazcan para los accionistas que quebranten estos límites, y si se omiten estas disposiciones, las estipulaciones se tienen por no escritas.

El establecimiento de porcentajes máximos de control es una innovación total en materia societaria, y podría obligar a un accionista a vender acciones, limitando la libre cesibilidad.

Si la constitución se hizo por escritura pública, la infracción a este tipo de disposición da lugar a un juicio ejecutivo, mientras que, si se hizo por instrumento privado, debe iniciarse un juicio declarativo.

El estatuto también puede establecer que, bajo ciertas circunstancias, se pueda exigir la venta de las acciones a todos o parte de los accionistas, sea a favor de otro accionista, de la sociedad o de terceros. Si existen tales normas, el estatuto debe contener disposiciones que regulen los efectos y establezcan las obligaciones y derechos que nazcan para los accionistas. En su defecto, dichas estipulaciones se tienen por no escritas.

Las acciones pueden ser **ordinarias o preferentes**, y el estatuto social debe establecer en forma precisa las cargas, obligaciones, privilegios o derechos especiales que afecten o de que gocen una o más series de acciones.

No es de la esencia de las preferencias su vinculación a una o más limitaciones en los derechos de que pudieran gozar las demás acciones.

Cada accionista dispone de un **voto** por cada acción que posea o represente. Sin embargo, el estatuto puede contemplar series de acciones sin derecho a voto, con derecho a voto limitado o a más de un voto por acción, en cuyo caso se debe determinar la forma de computar dichas acciones para el cálculo de los quóruns.

Esto es una diferencia con la Sociedad Anónima, ya que en tales sociedades no puede establecerse que una acción o serie de acciones tengan derecho a más de un voto por acción.

La sociedad puede **adquirir y poseer acciones de su propia emisión**, salvo en cuanto esté prohibido por el estatuto social. Con todo, las acciones de propia emisión que se encuentren bajo el dominio de la sociedad, no se computan para la constitución del quórum en las asambleas de accionistas o aprobar modificaciones del estatuto social, y no tienen derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital.

Las acciones adquiridas por la sociedad deben enajenarse dentro del plazo que establezca el estatuto. Si éste nada señala al respecto, deben enajenarse en el plazo de un año a contar de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las acciones no se enajenan, el capital se reduce de pleno derecho y las acciones se eliminan del registro.

La sociedad puede también emitir **acciones de pago**, las cuales se ofrecen al precio determinado libremente por los accionistas o por quien fuera delegado al efecto por ellos. No es obligatorio que esta oferta se realice preferentemente a los accionistas.

Sin embargo, el estatuto puede establecer que las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad o de valores convertibles en acciones de la sociedad, o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre éstas, sean de pago o liberadas, deban ser ofrecidos, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas, a prorrata de las acciones que posean.

Estando pendiente una emisión de bonos convertibles en acciones, debe permanecer vigente un margen no suscrito del aumento de capital por la cantidad de acciones que sea necesaria para cumplir con la opción, cuando ésta sea exigible conforme a las condiciones de la emisión de los bonos respectivos.

Conforme al **Art. 440**, todo **acuerdo de reducción de capital** debe ser adoptado por la mayoría establecida en el estatuto, y en silencio de éste, se requiere el voto conforme de la unanimidad de los accionistas.

No puede procederse al reparto o devolución de capital o a la adquisición de acciones con que dicha disminución pretenda llevarse a cabo, sino desde que quede perfeccionada la modificación estatutaria.

5. Resolución de Conflictos

Según dispone el **Art. 441**, las diferencias que ocurran entre los accionistas, entre los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y entre la sociedad y sus administradores y liquidadores, deben resolverse por medio de arbitraje.

A tal respecto, los estatutos deben indicar:

- El tipo de arbitraje y el número de integrantes del tribunal arbitral;
- El nombre o la modalidad de designación de los árbitros y sus reemplazantes.

En caso de omitirse la primera indicación, conoce de las disputas en única instancia un solo árbitro de carácter mixto, que no obstante actuar como arbitrador en cuanto al procedimiento, resuelve conforme a derecho.

En caso de omitirse la segunda indicación, los árbitros son designados por el tribunal competente en el lugar del domicilio social.

6. Pago de Dividendos

Conforme al **Art. 442**, en caso que el estatuto establezca que la sociedad deba pagar un dividendo por un monto fijo, determinado o determinable, a las acciones de una serie específica, éstos se pagan con preferencia a los dividendos a que pudieren tener derecho las demás acciones.

Salvo que el estatuto señale algo distinto, si las utilidades no fueran suficientes para cubrir el dividendo fijo obligatorio, el accionista puede optar por alguna de las siguientes opciones:

- Registrar el saldo insoluto en una cuenta especial de patrimonio creada al efecto y que acumulará los dividendos adeudados y por pagar. La sociedad no puede pagar dividendos a las demás acciones que no gocen de la preferencia de dividendo fijo obligatorio, hasta que la cuenta de dividendos por pagar no haya sido completamente saldada. En caso de disolución de la sociedad, el entero de la cuenta de dividendos por pagar tendrá preferencia a las distribuciones que deban hacerse;
- Ejercer el derecho a retiro respecto de las acciones preferidas a partir de la fecha en que se declare la imposibilidad de distribuir el dividendo. Si el estatuto no señalare otra cosa, el precio a pagar será el valor de rescate si lo hubiere o en su defecto el valor libros de la acción, más la suma de los dividendos adeudados a la fecha de ejercer el derecho de retiro.

Luego, según dispone el **Art. 443**, en caso que la sociedad deba pagar dividendos provenientes de las utilidades de unidades de negocios o activos específicos de ésta, debe llevar cuentas separadas respecto de ellos y las utilidades sobre las que se pagan dichos dividendos se calculan exclusivamente sobre la base de esta contabilidad, sin importar los resultados generales de la sociedad.

Por su parte, la sociedad no computa las cuentas separadas para el cálculo de sus utilidades generales, en relación con el pago de dividendos ordinarios a los accionistas.

Las ganancias provenientes de las unidades de negocios o activos separados que no sean distribuidas como dividendos se integran a los resultados generales del ejercicio correspondiente.

7. Medios de Comunicación

Conforme al **Art. 445**, el estatuto debe establecer los medios de comunicación entre la sociedad o los accionistas, siempre que den razonable seguridad de su fidelidad.

En silencio del estatuto, se utiliza el correo certificado, y el envío deficiente no afecta la validez de la citación, pero la administración responde de los perjuicios causados a los accionistas.

8. Traspasos de Acciones

Según dispone el **Art. 446**, en los traspasos de acciones debe constar la declaración del cesionario en el sentido que conoce la normativa legal que regula este tipo social, el estatuto de la sociedad y las protecciones que en ellos puedan o no existir respecto del interés de los accionistas.

La omisión de esta declaración no invalida el traspaso, pero hace responsable al cedente de los perjuicios que ello irroge.

Unidad VI – Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

1. Introducción

El legislador consideró, y con cierta razón, que en materia comercial existen personas a las que no les gustan las sociedades. Hay gente que prefiere trabajar sola y para la cual el modelo societario no es conveniente.

Se hizo necesaria entonces la creación de un modelo especial a través del cual una sola persona pudiera tener una empresa sin necesidad de asociarse con otras personas.

Por ello se dictó en 2003 la **Ley N°19.857**, autorizando a toda persona natural el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL).

El **Art. 2° de la Ley** define a la EIRL como una persona jurídica con patrimonio propio y distinto al del titular, que es siempre comercial y se somete al Código de Comercio cualquiera sea su objeto, y que puede realizar toda clase de operaciones civiles y mercantiles, salvo las reservadas por la ley a las sociedades anónimas.

Era necesario disponer que existe un patrimonio distinto al del titular, ya que al ser una sola persona pueden generarse confusiones.

La separación de los patrimonios es importantísima, ya que de otra forma los acreedores pueden perseguir los bienes propios del titular, conforme al derecho general de prenda.

Respecto a que siempre es mercantil, nos remitimos a la discusión que se mencionó al respecto de las sociedades anónimas.

2. Constitución de la EIRL

De conformidad al **Art. 3° de la Ley**, la constitución debe hacerse por escritura pública, la cual se inscribe y publica con arreglo a los **Arts. 4° y 5°**.

Según dispone el **Art. 4°**, las menciones mínimas de la escritura son:

- Nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil, edad y domicilio del constituyente;
- Nombre de la empresa, que debe contener, al menos, el nombre y apellido del constituyente, pudiendo tener también un nombre de fantasía, sumado al de las actividades económicas que constituyen en objeto o el giro de la empresa, y debe concluir con las palabras “*empresa individual de responsabilidad limitada*” o la abreviatura “*EIRL*”;
- El monto del capital que se transfiere a la empresa, la indicación de si se aporta en dinero o en especies y, en este último caso, el valor que se les asigna;
- La actividad económica que constituye el objeto o giro de la empresa y el ramo o rubro específico en que dentro de ella se desempeña;
- El domicilio de la empresa;
- El plazo de duración de la empresa, sin perjuicio de su prórroga. Si nada se dice, se entiende de duración indefinida.

Se exige el estado civil del constituyente a efectos de saber si está sujeto a un régimen patrimonial, como la sociedad conyugal, por ejemplo.

Respecto del capital, el **Art. 8°** dispone que la empresa responde exclusivamente por las obligaciones contraídas dentro de su giro con todos sus bienes, y que el titular sólo responde con su patrimonio propio por el pago efectivo del aporte que se hubiera comprometido a realizar en conformidad al acto constitutivo y sus modificaciones.

Si un acreedor quisiera demandar, tendría que demandar a la empresa, pero si no tiene bienes suficientes porque no se realizó total o completamente el aporte, el acreedor puede demandar al titular para que efectúe el pago del aporte y así pueda demandar a la empresa.

Respecto del objeto, siempre se habla en singular, por lo que se entiende que no puede tener un objeto múltiple, aunque ello ha sido muy discutido. Lo mejor, para evitar problemas, es hacer más de una EIRL si hay más de un objeto.

En caso de muerte del titular, podría continuar la empresa con los herederos, pero eso en la práctica podría presentar un riesgo para los acreedores. Por lo mismo, el **Art. 15 e)** dispone que la muerte del titular pone término a la EIRL. En estos casos, sin embargo, los herederos pueden designar un gerente común para la continuación del giro de la empresa por hasta un año, al cabo del cual termina la responsabilidad limitada.

El **Art. 5°** dispone que un extracto de la escritura pública, autorizado por el notario ante quien se otorgó, debe inscribirse en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa, y publicarse por una vez en el Diario Oficial, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura.

El extracto debe contener un resumen de las menciones señaladas en el **Art. 4°**.

En cuanto a las **modificaciones**, cualquiera que se haga respecto de las menciones del **Art. 4°** debe observar las mismas solemnidades que establece el **Art. 3°** para la constitución, y en el extracto debe hacerse referencia al contenido específico de la modificación.

La omisión de alguna de las solemnidades de los **Arts. 3°-6°** importa la nulidad absoluta del acto respectivo. Si se trata de la nulidad absoluta del acto constitutivo, el titular responde personal e ilimitadamente de las obligaciones contraídas en el giro de la empresa.

Todo esto, no obstante, se entiende sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley.

3. Administración de la EIRL

Conforme al **Art. 9°**, son actos de la empresa los ejecutados bajo el nombre y representación de ella por su administrador.

La administración corresponde al titular de la empresa, quien la representa judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, con todas las facultades de administración y disposición.

Ahora bien, el titular o su mandatario debidamente facultado, pueden designar un gerente general, que tiene todas las facultades del administrador, salvo las que excluya expresamente, mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio del domicilio social, y anotada al margen de la inscripción estatutaria.

Luego, según lo dispuesto en el **Art. 10°**, los actos y contratos que el titular de la empresa individual celebra con su patrimonio no comprometido en la empresa, por una parte, y con el patrimonio de la empresa, por la otra, sólo tienen valor si constan por escrito y desde que se protocolicen ante notario público.

Estos actos y contratos se anotan al margen de la inscripción estatutaria dentro del plazo de sesenta días contados desde su otorgamiento.

Esta es posiblemente la norma más importante dentro de la estructura de las EIRL, ya que establece la posibilidad de autocontratación, para lo cual hay que seguir los requisitos que establece el mismo artículo.

En caso de no cumplir con estos requisitos, el **Inc. 2° del Art. 10°**, en relación con el antiguo **Art. 471 CP** (delito de otorgamiento de contrato simulado), establece que la pena se aumenta en un grado si el delito es cometido por el titular de una EIRL.

Cabe preguntarse sobre la posibilidad de querellarse en contra del empresario individual por administración desleal. El profesor no ha visto un caso en que se haya intentado, pero en la práctica podría ser posible, dado que se administra un patrimonio distinto al del titular, y siendo un delito de acción penal pública, bastaría con una denuncia para que el fiscal formalice una investigación si existen hechos que podrían ser constitutivos de delito, pudiendo aplicar incluso lo dispuesto en el **Art. 10°** respecto del **Art. 471 CP**.

4. Responsabilidad del Titular

Tal y como lo indica su nombre, esta empresa individual es de responsabilidad limitada, y por lo mismo, el titular sólo responde hasta el monto del aporte realizado.

Las utilidades líquidas de la empresa pertenecen al patrimonio del titular, separado del patrimonio de la empresa, y una vez retiradas, no hay acción contra ellas por obligaciones de la empresa (**Art. 11**).

Si se tiene un juicio en contra de una EIRL, se debe pedir una precautoria sobre las utilidades para que no puedan ser retiradas.

Sin perjuicio de todo esto, existen ciertos casos en que el titular responde ilimitadamente con sus bienes, los cuales contempla el **Art. 12**, y que son los siguientes:

- Por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa, para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos;
- Por los actos y contratos que se ejecutaren sin el nombre o representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos;
- Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato;
- Si el titular percibiere rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro, o efectuare retiros que no correspondieren a utilidades líquidas y realizables que pueda percibir;
- Si el titular, los administradores o representantes legales hubieren sido condenados por los delitos concursales regulados en el Párrafo 7 del Título IX del Libro II del Código Penal.

Respecto del primer caso, debemos recordar la teoría de la accesoriedad, en virtud de la cual los actos civiles que complementan un giro mercantil se encuentran mercantiles y se rigen por las normas del Código de Comercio.

Si tengo una EIRL de venta de hamburguesas, y a la vez contrato servicios de transporte para mis trabajadores, es necesario defender la accesoriedad de tales servicios al giro, ya que de otra forma la empresa de transportes podría demandar en contra de mis propios bienes, entendiendo que es un acto o contrato efectuado fuera del giro de la empresa.

5. Transformación de una Sociedad en una EIRL

De conformidad al **Art. 14**, si se produce la reunión en manos de una sola persona de las acciones, derechos o participaciones en el capital de cualquier sociedad, ésta puede transformarse en empresa individual de responsabilidad limitada, cumpliendo su propietario con las formalidades de constitución establecidas en la **Ley N°19.857**.

Para tal efecto, la escritura pública respectiva, en la que debe constar la transformación y la individualización de la sociedad que se transforma, debe extenderse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que dicha reunión se produzca, y el extracto correspondiente debe inscribirse y publicarse dentro del término establecido en la presente ley.

Por su parte, una empresa individual de responsabilidad limitada podrá transformarse en una sociedad de cualquier tipo, cumpliendo los requisitos y formalidades que establece el estatuto jurídico de la sociedad en la cual se transforma.

6. Disolución de la EIRL

La disolución de la EIRL está regulada en el **Art. 15** de la ley, que contempla las siguientes causales:

- Por la voluntad del empresario;
- Por la llegada del plazo previsto en el acto constitutivo;
- Por el aporte del capital de la empresa individual a una sociedad;
- Por dictarse la resolución de liquidación;
- Por la muerte del titular.

Respecto de los dos primeros casos no es necesario profundizar, así como tampoco en el cuarto caso.

Si es importante hablar del tercer caso, es decir, de la disolución de la sociedad por el aporte del capital de la empresa individual a una sociedad. Esto puede suceder, por ejemplo, por una fusión o una absorción, mediante las cuales se transfiere todo el patrimonio de la empresa como aporte a otra sociedad, poniendo fin a la EIRL.

En cuanto al último caso, mencionamos anteriormente que la muerte del titular pone término a la EIRL, pero que en estos casos, sin embargo, los herederos pueden designar un gerente común para la continuación del giro de la empresa por hasta un año, al cabo del cual termina la responsabilidad limitada.

Transcurrido el año, responden por sus propios bienes, y lo mejor, si se quiere continuar, es constituir una nueva empresa, o bien transformarla en una sociedad.

7. Legislación Aplicable

Conforme al **Art. 18**, se aplican a la EIRL todas las disposiciones legales y tributarias aplicables a las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, incluyendo las normas de saneamiento de vicios de nulidad.

Esto nos importa sobre todo por el tema tributario, ya que el titular de la empresa podría ser un contribuyente de segunda categoría, pero al aportar su sueldo a la EIRL, pasa a ser contribuyente de primera categoría.

8. Sociedades por un Día

Por último, estudiaremos las llamadas Sociedades por un Día, introducidas por la **Ley N°20.659**, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.

Todo apunta que tenemos que hacer algo para modificar el sistema de constitución de las sociedades, simplificándolo para hacerlo por medios digitales.

Conforme a la ley, las siguientes personas jurídicas pueden ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas o disueltas cumpliendo solamente con las solemnidades dispuestas en la misma ley:

- La EIRL;
- La Sociedad de Responsabilidad Limitada;
- La Sociedad Anónima Cerrada;
- La Sociedad Anónima de Garantía Recíproca;
- La Sociedad Colectiva Comercial;

- La Sociedad por Acciones;
- La Sociedad en Comandita Simple;
- La Sociedad en Comandita por Acciones.

Conforme al **Art. 4º**, as personas jurídicas que se acojan a esta ley son constituidas, modificadas, fusionadas, divididas, transformadas, terminadas o disueltas, según sea el caso, a través de la suscripción de un formulario por el constituyente, socios o accionistas, el que deberá incorporarse en el Registro de Empresas y Sociedades que al efecto lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

La suscripción de los formularios, conforme al **Art. 9º**, se realiza mediante la firma del constituyente, socios o accionistas, según sea el caso, a través de la firma electrónica avanzada.

Según dispone el **Art. 5º**, el contrato social y el estatuto de las personas jurídicas que se acojan a esta ley será aquel que conste en el formulario de constitución inscrito en el Registro y en las modificaciones introducidas en la forma establecida en la ley, según corresponda.

En el silencio del acto constitutivo, las personas jurídicas se regirán por las normas que les sean aplicables conforme a su especie.

El problema es que este sistema es tan lineal y busca ser tan simple, que se generan abusos, faltas de confianza y conflictos.

En opinión del profesor, puede generar varias complicaciones, sobre todo en sede judicial, pero puede ser muy útil en ciertos casos, sobre todo para empresas pequeñas.

La responsabilidad de los socios, accionistas y constituyentes es la que determina la ley para cada clase de sociedad. Lo único que cambia es la forma de constitución.